

서인 판결서에 같은 오류가 명백한 경우에 하는 판결결정(민소법 제211조)과 유사하고, 이 경정결정은 판결과 일체가 되어 경정결정 자체의 효력과는 달리 판결선고시에 소급하여 그 효력이 발생하며, 그리하여 처음부터 경정된 내용대로의 판결이 선고된 것과 같이 되는 것인바,²²⁴⁾ 같은 공문서 정정의 효력을 전자에 한해서만 소급효를 인정하지 아니할 특별한 이유를 발견하기 어려우므로 양자의 정정 또는 경정의 효력은 모두 공탁수리 또는 판결선고 당시로 소급한다고 봄이 상당하다. ③ 공탁규칙 제30조 제5항은 “수리의 취지가 기재된 공탁서정정신청서는 공탁서의 일부로 본다.”라고 규정하고 있는 바, 여기서 「공탁서의 일부로 본다」라 함은 가령 공탁서 중 반대급부조건 표시란에 기재하였던 부당조건을 삭제하여 없는 것으로 한 정정신청서라면 그것이 본래의 공탁서의 반대급부조건 표시란을 대신한다는 뜻이므로 위 공탁서는 정정 결과 반대급부 표시란이 공란으로 되는 것이어서 위 정정의 효력은 결국 이 규정에 의하여 결론적으로 소급효를 인정한 것으로 된다. ④ 공탁서의 정정은 수리된 공탁서 중의 일부분에 공탁자의 의사에 합치하지 아니하는 착오부분이 존재함을 발견하여 공탁자가 그 부분을 취소·철회하는 것으로서, 마치 민법 제109조에 따른 착오의사표시의 취소와 유사한 것이라 할 것이고, 다만 다른 점은 그것이 공문서가 된 후에 발견한 관계로 이를 취급하는 공탁관의 승인을 받아서 취소한다는 점 뿐인바, 의사표시를 철회·취소하면 그와 같은 의사표시는 당초부터 없었던 것으로 뒀은 또한 당연하다. ⑤ 위 판례에 따르면 공탁서 정정에 의하여 부당반대급부조건을 취소·철회한 경우에 그 정정시까지의 변제공탁은 무효였다가 정정으로 무효였던 변제공탁이 유효한 것으로 전환한다고 보거나 또는 정정시에 정정한 대로 새로운 변제공탁이 성립된 것으로 보게 될 것이나, 부당조건부 변제공탁은 착오의사표시라고 하는 하자가 내재한 공탁으로서 이 하자를 제거하면 당초부터 하자가 없는 완전한 변제공탁이 된다고 보는 것이 위 공탁법규의 입법취지에도 부합한다 할 것이다.“라는 등의 많은 논거를 들어 이를 비판한 후 소급설을 취하는 견해가 있고,²²⁵⁾ 이러한 소급설은 앞서 본 우리 공탁규칙 제30조 제1항이 공탁서 정정에 있어서 「동일성을 해하지 아니하는 범위 내에서」란 요건을 고수하고 있는 점에 비추어 상당히 합리적인 견해라고 생각된다.

224) 대법원 1962. 1. 25. 선고 4294민재항674 판결 참조

225) 남기정, 앞의 실무공탁요론, 268-271.

제4절 사유신고

(민집 제248조 제4항, 제236조 제2항)

I. 의의

압류명령이 제3채무자에게 송달되면 채권압류의 효력이 발생하고, 제3채무자는 본래의 채권자인 집행채무자에 대한 지급이 금지된다(민집 제227조 제1항, 제3항). 그 결과, 제3채무자는 압류채권자의 추심권 행사에 응하여 지급하든가 혹은 공탁해야만 채무를 면하게 되는 것이다.

위 공탁에는 이미 본 것처럼 권리공탁과 의무공탁이 있지만, 제3채무자는 어느 공탁을 한 경우에도 그 사유를 집행법원에 신고해야 한다(민집 제248조 제4항).

집행법원은 제도상 이 신고에 의해서 공탁사실을 알게 된다. 역으로 말하면, 이 신고가 없으면 집행법원은 공탁사실을 알 방법이 없는 것이다.

이러한 신고를 제3채무자의 사유신고라 하고, 이러한 사유신고가 있을 때에 비로소 배당요구의 종기에 이르게 된다(민집 제247조 제1항 제1호).

그리고 민사집행법 제252조 제2호는 제3채무자가 같은 법 제248조의 규정에 따라 공탁한 때에 배당절차가 개시된다고 규정하고 있지만, 제3채무자가 공탁하였다 하더라도 그 사실을 집행법원에 사유신고하지 않는 한 집행법원이 이를 알 수 있는 방법이 없으므로 실재상 제3채무자가 위와 같이 사유신고를 해야만 배당절차를 개시할 수 있게 된다고 보아야 할 것이다.

또한 추심채권자는 제3채무자로부터 추심한 금액을 집행법원에 신고하여야 하고, 그 신고 전에 다른 압류·가압류 또는 배당요구가 있었을 때에는 추심한 금액을 바로 공탁하고 그 사유를 신고하여야 하는바(민집 제236조 제1항, 제2항), 이를 가리켜 추심채권자의 사유신고라고 할 수 있지만, 이에 관해서는 앞에서 본 바 있으므로 여기에서는 제3채무자의 사유신고를 중심으로 논의해 가기로 한다.

II. 사유신고의 방식, 내용, 제출 법원 등

1. 일반 제3채무자인 경우

가. 사유신고서의 제출내용 등

- 1) 사유신고서에는 위와 같이 사건 및 당사자의 표시, 공탁사유와 공탁한 금액

등을 기재하여야 한다(민집규 제172조 제1항).

2) 민사집행법 제248조 제4항이 규정하는 사유신고는 다음과 같이 세 가지로 구분할 수가 있다.

즉 ① 가압류만 집행된 채권에 대하여 제3채무자가 민사집행법 제291조, 제248조 제1항에 따라 공탁한 다음 사유신고를 하는 경우, ② 압류가 경합되지 않은 때, 즉 압류가 1개이거나 또는 집행이 경합되어 있지만 압류의 경합이 아닌 경우에 제3채무자가 민사집행법 제248조 제1항에 따라 공탁한 후 사유신고를 하는 경우, 그리고 ③ 압류된 채권에 대하여 배당요구가 있거나 혹은 압류의 경합이 있는 때에 민사집행법 제248조 제1항 내지 제3항에 의해 공탁한 후 사유신고를 하는 경우 등이 그것이다.

3) 위 가운데 ③의 경우라면, 제3채무자는 「압류집행이 있는 사실 + 압류가 경합된 사실(혹은 배당요구가 있는 사실) + 압류에 관련된 채권액을 공탁한 사실」을 사유신고서에 적게 되는데, 이 사유신고는 집행법원에 대해 배당절차를 진행함으로써 권리자를 확정시켜 달라는 취지로 행해지는 것이다.

그리고 위 ②의 경우에는 사유신고서에 「압류집행이 있는 사실 + 압류에 관련된 채권액을 공탁한 사실」을 적게 되는데, 이는 집행법원에 대하여 교부절차를 진행함으로써 권리자를 확정시켜 달라는 취지로 행해지는 것이다. 위 ②③의 경우에는 모두 그 사유신고서에 배당등 절차사건으로 접수되어 사건번호가 부여되는 것이다.

그런데 위 ①의 경우에는 이와 좀 다르다. 즉 가압류된 채권의 경우에는 위와 같은 집행공탁이 행해지더라도 민사집행법 제297조가 규정하는 바와 같이 배당가입의 차단효과 발생하지 않고, 또 그 사유신고도 집행법원이 아닌 가압류발령법원에 대해 행해지는 것이다. 따라서 이 경우에는 사유신고서에 「가압류집행이 있는 사실 + 가압류에 관계된 채권액을 공탁한 사실」을 기재하고 가압류발령법원에 사유신고를 하는바, 그 취지는 단지 사유신고서에 기재된 사실을 가압류발령법원에 인식시키는 의미밖에 갖고 있지 않다(따라서 이 경우 명칭을 공탁사유신고서로 하기보다는 그저 ‘공탁신고서’라고 함으로써 그것이 다른 경우의 사유신고와 다름을 표시하고 있는 것이 실무레이다).

이때에는 가압류의 집행을 원인으로 하여 제3채무자가 공탁을 한 후, 가압류채권자 또는 다른 채권자가 공탁관을 제3채무자로 하여 채무자가 가지는 출급청구권에 대하여 압류의 집행을 한 때에 비로소 배당가입의 차단효과 발생하게 되는데,²²⁶⁾ 이

226) 東京地裁債權執行等手續研究會(주57), 228.

경우 만약 가압류채권자가 본압류로 이전한 경우라면 채권의 동일성을 확인하고 배당 등 절차의 개시 가능 여부를 명확히 하기 위하여 공탁관은 집행법원에 대해 이에 기초한 사유신고를 해야 한다(이에 대한 자세한 논의는 앞서 본 제2절 Ⅸ. 3. 부분 참조).²²⁷⁾

4) 제3채무자가 상당한 기간 내에 공탁사유신고를 하지 않으면 압류채권자, 가압류채권자, 배당에 참가한 채권자, 채무자 그 밖의 이해관계인이 그 사유를 법원에 신고할 수 있다(민집 제248조 제4항).

이는 제3채무자가 공탁을 하였더라도 사유신고를 하지 않는 한 배당요구의 종기가 도래하지 아니하여 배당등의 절차가 사실상 진행되지 못하는 등 절차의 신속한 진행에 지장이 있으므로 다른 이해관계인에게 사유신고권을 더불어 인정한 것이다(그러나 이것이 오히려 제3채무자가 사유신고를 해태하게 되는 원인이 될 수 있다는 것에 대하여는 나중에 살펴볼 것이다).

나. 사유신고서 제출 법원 등

1) 압류명령을 송달받은 제3채무자는 채권자가 경합되지 않는 경우라면 원칙적으로 당해 압류명령을 발령한 법원에 사유신고를 하여야 한다.

2) 채권자가 경합된 경우라면 그것이 진정한 압류 경합이 아닌 경우(압류명령의 집행채권의 총액이 피압류채권액을 넘지 않는 경우)이든 아니면 진정한 압류의 경합이 있는 경우이든 구별하지 않고 먼저 송달된 압류명령을 발령한 법원에 사유신고를 하여야 한다(민집규 제172조 제3항).

3) 그리고 가압류와 본압류가 경합된 경우에는 본압류를 발령한 법원에 사유신고를 하여야 한다.

따라서 뒤에 송달된 압류명령 또는 가압류와 압류가 경합된 경우에 가압류발령 법원에 사유신고서가 제출된 경우에는 먼저 송달된 법원 또는 본압류 발령법원으로 배당사건을 이송함이 상당하다.²²⁸⁾

4) 가압류명령만을 송달받은 제3채무자는 공탁을 한 후 공탁서를 첨부하여 가압류 발령법원에 사유신고를 해야 하고, 둘 이상의 가압류가 있는 경우에는 먼저 송달된 가압류 발령법원에 신고해야 한다.²²⁹⁾

227) 대법원 행정예규 제1018호 「제3채무자의 권리공탁에 관한 업무처리절차」 참조

228) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355.

229) 대법원 행정예규 제1018호, “제3채무자의 권리공탁에 관한 업무처리절차”

5) 또한 이러한 집행공탁과 그에 이은 사유신고 뒤에는 압류채권자는 압류명령신청을 취할 수 없고, 취하하더라도 자신의 배당금수령권을 포기하는 효과가 있을 뿐, 배당등의 절차를 진행하는데 있어서 영향이 없다(다만 가압류채권자의 경우에는 배당가입의 차단효과 발생하지 않으므로 취하 등이 가능하다).²³⁰⁾

2. 제3채무자가 공탁관인 경우(공탁관의 사유신고)

가. 개념 및 절차

공탁관의 사유신고라 함은 공탁금의 출급·회수청구권에 대한 압류의 경합 등이 있는 경우에 제3채무자인 국가(공탁관)가 공탁을 지속하면서 그 사실을 집행법원에 신고하는 것을 말한다.

공탁관은 사유신고를 할 사정이 발생한 때에는 지체 없이 사유신고서 2통을 작성하여 그 1통을 관할 집행법원에 송부하고 다른 1통은 당해 공탁기록에 편철한다(공탁규칙 제58조 제1항). 이때에 공탁관은 원표에 사유신고한 취지와 그 연월일을 기재하여야 한다(위 규칙 제58조 제2항).

제3채무자가 국가이고 그 소관이 공탁관인 때에는 재공탁을 하지 않고 종전의 공탁을 그대로 유지하면서 사유신고를 하기 때문에 공탁서원본을 첨부할 수 없고 공탁서부본을 사본하여 첨부하면 되며, 경합된 압류·가압류 또는 배당요구통지서 등의 사본도 첨부하여야 한다(대법원 행정예규 제542호).

압류가 경합하고 있는데 각 압류명령의 발령법원이 다른 경우, 이에 관한 규정이 없던 구 민소법하에서는 어떤 집행법원에 대하여 사유신고를 해도 무방하다고 해석하고 있었으나(대법원 행정예규 제542호, 다만 해당 공탁소 관할법원이 포함된 경우라면 특별한 사정이 없는 한 그 법원에 사유신고를 해야 한다고 규정함), 이에 관하여 이제는 민사집행규칙 제172조 제3항이 명문으로 이를 규정하고 있으므로 그에 따라 먼저 송달된 압류명령을 발령한 법원에 사유신고를 하여야 할 것이다(위 예규의 개정이 필요함).

또한 가압류와 본압류가 경합하는 경우에는 본압류를 발령한 법원에 사유신고를 하여야 한다.

나. 사유신고의 요건

공탁관이 사유신고를 하기 위해서는 ① 압류의 경합이 있을 것 ② 지급요건이

230) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355-356. 참조

충족되었을 것 등의 요건이 갖추어져야만 한다(대법원 행정예규 제542호 참조).

1) 압류의 경합이 있을 것

가) 공탁관의 사유신고를 위해서는 먼저, 공탁금지급청구권에 대하여 채권자 경합이 생기고, 집행채권의 총액이 피압류채권의 총액을 초과하여 재판상 배당을 필요로 하는 경우이어야 한다.

따라서 ㉠ 압류명령을 송달받은 후 다른 채권자의 배당요구통지를 받은 때 ㉡ 압류(또는 가압류명령)를 송달받은 후 다른 채권자의 전부(추심)명령을 송달받은 때 ㉢ 압류명령을 송달받은 후 다른 채권자의 압류명령 또는 가압류명령을 송달받은 때에 사유신고가 가능하고, 특별히 판례²³¹⁾는 동일한 채권액에 대하여 복수의 압류명령 등이 있더라도 각 압류의 법률적 성질상 압류액의 총액이 피압류채권액을 초과하지 아니하여 본래의 의미에서의 압류의 경합으로 볼 수 없는 경우에도, 제3채무자의 입장에서 보아 그 우선순위에 대하여 문제가 있는 등 압류의 경합이 있는지 여부에 관한 판단이 곤란하다고 보이는 객관적 사정이 있는 경우에는 구 민소법 제581조 제1항의 규정을 유추적용하여 사유신고를 할 수 있다고 보고 있다.

나) 이와 다른 한편, 압류가 경합하지 않는 경우, 즉 ㉠ 복수의 가압류만 있는 경우 ㉡ 가압류와 체납처분에 의한 압류가 있는 경우(그 선후를 불문한다) ㉢ 체납처분에 의한 압류가 선행하고 강제집행에 의한 압류가 후행하는 경우(다만 강제집행에 의한 압류가 선행하고 체납처분에 의한 압류나 참가압류 또는 교부청구가 후행한 경우에는 압류의 경합에 준하여 처리한다), ㉣ 압류 및 전부명령이 있는 이후에 가압류나 압류 등이 있는 경우 ㉤ 공탁금지급청구권이 제3자에게 양도되어 대항요건을 갖춘 후에 압류, 가압류 등이 경합한 경우 ㉥ 선행의 압류(또는 가압류) 후에 목적채권인 공탁금지급청구권이 제3자에게 양도되어 대항요건을 갖춘 후 압류, 가압류 등이 경합한 경우 ㉦ 금전공탁이 아닌 유가증권 또는 물품공탁의 지급청구권에 대하여 압류가 경합된 경우 등에는 복수의 압류가 있고 집행채권의 총액이 피압류채권의 총액을 초과하고 있더라도 사유신고를 할 필요가 없다.

2) 지급요건이 충족되었을 것

가) 다음으로, 압류의 경합이 있더라도 더 나아가 공탁관이 압류채권자의 지급청구에 응하는 것이 가능한 때이어야만 사유신고를 할 수 있다.

231) 대법원 1996. 6. 14. 선고 96다5179 판결; 대법원 1998. 10. 20. 선고 98다31905 판결 등 참조

나) 그러므로 ① 재판상보증공탁금의 회수청구권에 대하여 압류의 경합이 있는 경우에는 추심권을 가진 압류채권자 또는 채무자(공탁자)가 공탁원인의 소멸을 증명하는 서면 또는 법원의 담보취소결정정본 및 확정증명서 등이 제출하거나 또는 공탁관이 그 사실을 안 때에, 재판상보증공탁금의 출급청구권에 대하여는 추심권을 가지는 압류채권자 또는 채무자(피공탁자)로부터 피담보채권의 존재를 증명하는 확정판결, 화해조서 등이 첨부되어 출급청구가 있는 때에 비로소 사유신고를 할 수 있다. 그리고 ② 변제공탁금의 회수청구권에 대하여는 압류채권자 또는 채무자(공탁자)로부터 공탁불수락으로 인한 회수청구가 있는 때에, 변제공탁금의 출급청구권에 대하여는 압류채권자 또는 채무자(피공탁자)로부터 공탁수락서 또는 공탁을 유효하다고 선언하는 취지의 확정판결정본이 제출되거나 그들로부터 공탁수락에 의한 출급청구가 있는 때에 비로소 공탁관은 사유신고를 할 수 있다. 또한 ③ 상대적 불확지공탁에 있어서 피공탁자 중 일방의 공탁금출급청구권에 대하여 압류의 경합이 있는 경우에는 당해 피공탁자에게 공탁금출급청구권이 있음이 증명된 때에 사유신고를 할 수 있다.

가압류해방공탁금의 회수청구권과 가압류집행에 기초한 공탁금(민집 제291조, 제248조 제1항)에 관한 피공탁자(가압류채무자)의 공탁금출급청구권에 대하여 다른 압류명령이 송달되어 압류의 경합이 생긴 경우 또는 피공탁자의 공탁금출급청구권에 대하여 공탁사유인 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령이 있는 경우에는 그 압류명령이 송달된 때에 즉시 압류명령을 발령한 법원에 사유신고를 할 수 있다.²³²⁾

다. 사유신고의 시기

공탁관은 일반적으로 공탁금지급청구권에 대한 압류의 경합 등으로 사유신고를 할 사정이 발생한 때(예컨대, 최후에 압류명령 등이 송달된 날)에는 그 다음날로부터 3일 이내에 집행법원에 사유신고를 해야 한다(대법원 행정예규 제542호).

그러나 위에서 본 바와 같이 압류의 경합 이외에 지급요건의 충족이 필요한 때에는 그 지급요건이 충족된 때에 사유신고를 하여야 한다(위 예규).

232) 대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다118785 판결(공탁사유인 가압류를 본압류로 이전하는 압류명령이 국가(공탁관)에게 송달되면 민사집행법 제291조, 제248조 제1항에 따른 공탁은 민사집행법 제248조에 따른 집행공탁으로 바뀌어 공탁관은 즉시 압류명령의 발령법원에 그 사유를 신고하여야 하는데, 이로써 가압류의 효력이 미치는 부분에 대한 채무자의 공탁금출급청구권은 소멸하고, 그 부분 공탁금은 배당재단이 되어 집행법원의 배당절차에 따른 지급위탁에 의하여만 출급이 이루어질 수 있게 된다고 판시); 대법원 행정예규 제1018호(제3채무자의 권리공탁에 관한 업무처리절차) 참조.

라. 사유신고의 효과 등

공탁관이 제3채무자로서 사유신고를 한 경우도 그 사유신고에 의하여 배당절차가 개시되고 배당요구의 중기가 확정된다(민집 제248조 제4항).

배당에 들어가 우선채권이 아닌 한 각 채권액에 비례하여 평등배당함이 원칙이지만, 예외적으로 가압류해방공탁금 회수청구권에 대한 가압류채권자의 가압류와 가압류채무자에게 해방공탁금 용도로 금원을 대여한 다른 채권자의 압류가 경합하여 공탁관이 사유신고한 때에는 그 배당절차에 있어서 가압류채권자에 대한 관계에서 가압류채무자에게 해방공탁금 용도로 금원을 대여한 다른 압류채권자는 압류의 효력을 주장하여 배당받을 수 없다는 대법원판결²³³⁾이 있다.

공탁금지급청구권에 대한 압류의 경합으로 공탁관이 집행법원에 사유신고를 한 이후에 다른 채권자로부터 압류나 가압류 등이 있더라도 추가로 사유신고를 할 필요는 없다.

Ⅲ. 사유신고의 수리·불수리의 문제

1. 의의

제3채무자로부터 사유신고가 제출되면, 집행법원은 그 사유신고 및 공탁서를 열람·심사하고 사유신고 및 공탁이 적법·적절한 것이라면 이를 수리하고 배당등 사건으로 접수하게 된다.

그런데 그 사유신고 또는 그 기초가 되는 공탁이 부적법 혹은 부적절한 경우라면 법원은 어떠한 조치를 취해야 하는 것일까.

이에 관해서는 명문의 특별한 규정이 없지만 이 경우 사유신고를 수리하지 않는 것(이른바 불수리)으로 처리해야 할 것이다. 다만 이러한 사유신고의 불수리에 관하여는 명문으로 이를 인정하는 규정이 없는데, 법원이 사유신고를 불수리하고 제3채무자가 공탁금을 반환하는 절차를 거쳐야 할 필요성까지 있는 경우에는 제3채무자는 공

233) 대법원 1998. 6. 26. 선고 97다30820 판결【판결요지】해방금액의 공탁에 의한 가압류 집행취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 가압류채권자의 가압류에 의하여 누릴 수 있는 이익이 가압류 집행취소에 의하여 침해되어서는 안되므로 가압류채무자에게 해방공탁금의 용도로 금원을 대여하여 가압류집행을 취소할 수 있도록 한 자는 비록 가압류채무자에 대한 채권자라 할지라도 특별한 사정이 없는 한 가압류채권자에 대한 관계에서 가압류 해방공탁금 회수청구권에 대하여 위 대여금 채권에 의한 압류 또는 가압류의 효력을 주장할 수는 없다.

탁에 의해서 얻을 수 있는 변제의 효과가 소멸되어버리는 불이익이 생길 수가 있기 때문에 법원으로서도 되도록 이를 불수리하기보다는 임의의 보정을 촉구하고, 또한 공탁에 관해서도 공탁서정정이 가능한 것은 정정하도록 하여 사유신고를 수리하는 방향으로 실무를 운용해 나가야 할 것이다. 또한 의문점이 있을 경우에는 바로 불수리로 하지 말고 제3채무자 등에게 조회를 해보는 것도 좋다.

그러나 법원의 이러한 노력에도 불구하고 실무상 사유신고를 수리할 것인지 여부가 문제될 수 있는 사안들이 있는바, 이하에서 몇 가지만 살펴보기로 한다.

2. 실무상 문제로 될 수 있는 사례들

가. 우선 첫째로, 공탁자가 제3채무자가 아닌 경우를 생각해볼 수 있다.

예컨대, 제3채무자인 법인이 공탁해야 되는 때에 대표자 개인 이름으로 공탁한 경우 또는 제3채무자의 친족이 공탁한 경우 등이다.

채권압류는 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 채권이 압류되어 있는 것이고, 제3채무자는 그 채무의 변제를 위하여 공탁하는 것이므로 제3채무자 이외의 자가 공탁하고 사유신고서를 제출한 때에는 압류된 채무가 아닌 채무가 공탁된 것으로 되며, 결국 집행법상의 공탁에 기초한 사유신고를 제출하지 않은 것으로 된다.

또한 집행공탁에 있어서는 제3자에 의한 공탁이 인정되지 않고 있다. 따라서 이상과 같은 공탁은 그 보정이 불가하므로 그에 따른 사유신고를 불수리로 처리하는 수밖에 없다.

나. 둘째로, 의무공탁(민집 제248조 제2항)을 하는 경우에는 경합하고 있는 모든 압류명령 등을 공탁원인 중에 표시해야 함에도 불구하고 공탁서의 공탁원인 및 사유신고서에 경합하는 압류명령 등의 표시가 일탈 또는 누락되어 있는 경우를 들 수 있다.

하지만 이런 경우에는 공탁서 기재에 관해서는 공탁소에 대해 공탁서정정신청을 하고, 사유신고에 관해서는 사유신고 보완서(정정서)를 제출함으로써 정정하는 것이 가능하다 할 것이므로 불수리로 하지 않고 그러한 정정 등의 절차를 거친 후에 사유신고서를 수리하면 될 것이다.

다. 셋째로, 피압류채권 이외의 채권을 공탁한 경우, 예를 들어 ㉠ 2018년 6월분 건물의 임료가 압류되어 있는데 2018년 4월분 임료를 공탁한 경우, ㉡ 어떤 아파트 305호실의 임료가 압류되어 있는데 405호실의 임료를 공탁한 경우, ㉢ 어떤 특정

한 컴퓨터의 매매대금이 압류되어 있는데 식료품매매대금을 공탁한 경우 등을 상정해 볼 수 있다.

이러한 경우에는 제3채무자가 압류된 채권과는 전혀 다른 것을 공탁하였기 때문에 공탁서 정정을 하기가 어렵고 당해 공탁이 부적법한 것으로 될 수밖에 없다. 따라서 이에 따른 사유신고는 불수리해야 할 것이다.

라. 넷째로, 제3채무자가 결정등의 효력을 잘 알지 못하고 공탁 후 사유신고한 경우인데, 이는 실무상 전부명령 후 다른 전부명령이나 추심명령을 송달받은 제3채무자가 그 효력 여부를 알지 못하고 공탁한 다음 사유신고를 한 경우에 있어서 나타나는 사례인바, 이 경우도 사유신고에 대해 불수리결정을 해야 할 것이다(다만 이 경우 전부채권자도 배당등을 받을 채권자의 범위에 포함될 수 있는 것이므로 일부 실무는 이때 그대로 배당절차를 진행하여 전부채권자에게 모두 배당하는 것으로 배당표를 작성하는 식으로 처리하기도 한다).

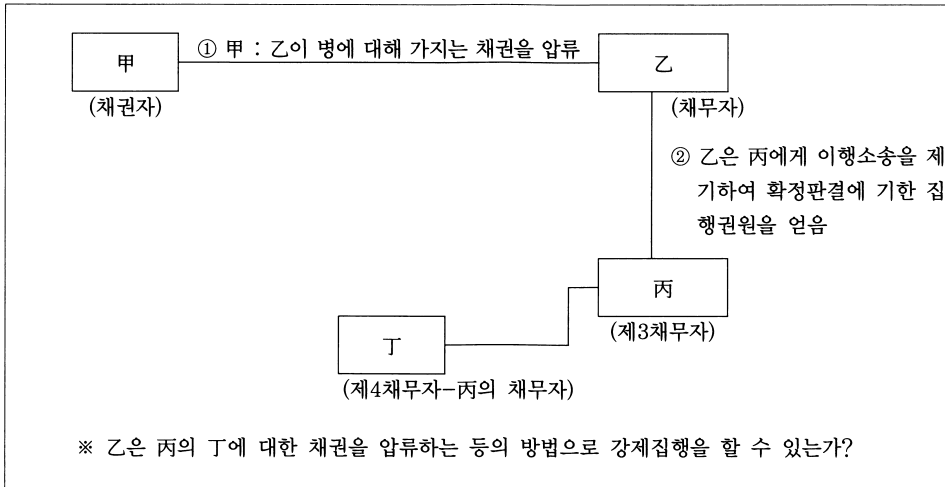
마. 다섯째로, 공탁관이 그 요건이 구비되어 있지 않는데도 불구하고 집행법원에 사유신고서를 제출한 경우를 들 수 있겠다.

즉 앞서 본 바와 같이 공탁관이 사유신고를 하기 위해서는 압류의 경합, 지급요건의 충족이라는 요건이 갖추어졌어야 함에도 불구하고 그 요건이 구비되지 않은 상태에서 사유신고를 제출한 것을 말한다.

이러한 사안은 예를 들어 가압류해방공탁금에 대하여 가압류채권자가 본안의 승소판결을 받은 후 가압류의 피보전권리와 압류의 집행채권의 동일성이 인정되는데도 불구하고 본압류로의 이전에 의한 압류명령을 신청하지 아니하고 바로 압류명령을 신청하여 마치 압류가 경합된 것과 같은 외관을 갖추게 되어 공탁관이 사유신고를 한 경우 등에서 찾아볼 수 있을 것이다.

이때는 일단 그 사유신고를 불수리하고, 다시 그 요건이 구비된 단계에서 사유신고서를 제출하면 될 것이다(다만 이 경우도 실무는 그대로 배당절차를 진행하여 당해 압류채권자에게 배당해주는 식으로 처리하기도 한다).

바. 그 밖에 다음과 같이 甲에 의하여 집행채권에 대한 압류 등이 있는 후에 그 채무자인 乙이 자신의 채권에 대하여 압류명령을 받은 경우에도 문제 된다.



이 경우 乙이 丙의 丁에 대한 채권을 압류할 수 있음에 대하여는 앞서 본 대법원 2000. 10. 2.자 2000마5221 결정과 대법원 2016. 9. 28. 선고 2016다205915 판결²³⁴⁾ 등이 이를 명시적으로 인정하고 있고, 이론상으로도 문제가 없다.

그런데 위 사례에서 채무자 乙에 대한 제3채무자 丁(채권자 甲의 입장에서 볼 때에는 제4채무자)은 丙의 자신에 대한 채권이 乙에 의해 압류되었으므로 민사집행법에 따른 공탁을 함으로써 채무를 면할 수 있다. 그러나 甲에 의해 이미 乙의 丙에 대한 채권이 압류된 상태에서 乙이 행한 채권압류명령은 보전적 처분으로서 유효한 것이고 현금화나 만족적 단계로 나아가는 데에는 집행장애사유가 존재하므로, 이를 원인으로 한 공탁에는 가압류를 원인으로 한 공탁과 마찬가지로 효력(민집 제297조 참조)만이 인정된다.²³⁵⁾ 따라서 위와 같은 공탁에 따른 사유신고는 부적법하고, 이로

234) 대법원 2016. 9. 28. 선고 2016다205915 판결; 대법원 2000. 10. 2.자 2000마5221 결정【결정요지】채권압류명령과 전부명령을 동시에 신청하더라도 압류명령과 전부명령은 별개로서 그 적부는 각각 판단하여야 하는 것이고, 집행채권의 압류가 집행장애사유가 되는 것은 집행법원이 압류 등의 효력에 반하여 집행채권자의 채권자를 해하는 일체의 처분을 할 수 없기 때문이며, 집행채권이 압류된 경우에도 그 후 추심명령이나 전부명령이 행하여지지 않은 이상 집행채권의 채권자는 여전히 집행채권을 압류한 채권자를 해하지 않는 한도 내에서 그 채권을 행사할 수 있다고 할 것인데, 채권압류명령은 비록 강제집행절차에 나간 것이기는 하나 채권전부명령과는 달리 집행채권의 환가나 만족적 단계에 이르지 아니하는 보전적 처분으로서 집행채권을 압류한 채권자를 해하는 것이 아니므로 집행채권에 대한 압류는 집행채권자가 그 채무자를 상대로 한 채권압류명령에 대해서는 집행장애사유가 될 수 없다.

235) 대법원 2016. 9. 28. 선고 2016다205915 판결. 가압류를 원인으로 한 공탁과 동일한 효력만이 인정된다는 것은, 이 경우 丁의 공탁 이후에도 배당가입차단효과 발생하지 않으므로, 이 경우 乙의 압류의 효력은 가압류의 효력만이 인정되고 그 가압류의 효력이 丙이 갖는 공탁금출급청구권 위에 존속하게 되며(민집 제297조), 채무자 丙의 다른 채권자들도 丙이 갖는 공탁금출급청구권에 대하여 다시 압류 또는 가압류, 처분금지가처분 등을 할 수 있다는 것을 의미한다.

인하여 채권배당절차가 실시될 수는 없으며, 만약 그 채권배당절차가 개시되었더라도 배당금이 지급되기 전이라면 집행법원은 공탁사유신고를 불수리하는 결정을 하여야 한다.²³⁶⁾

3. 사유신고의 불수리 방법 및 효과

사유신고서를 불수리하는 방법에 관해서도 현재 아무런 규정이 없다. 여기에는 법원사무관등이 불수리한 후 불수리증명서를 교부해주는 방법(당사자가 제출한 불수리증명신청서에 증명인을 날인해주는 방법)과 집행법원이 불수리결정을 한 다음 그 결정정본을 제3채무자에게 교부해주는 방법 등을 거론해 볼 수 있는데, 사유신고를 수리하기 전에 불수리 사유를 발견한 경우에는 전자의 방법에 의하는 것이 적절하고, 사유신고를 수리한 후에 착오 또는 오류에 의해 집행공탁을 하고 사유신고를 하였음을 발견한 경우에는 후자에 따라 집행법원이 불수리결정을 하는 것이 적절할 것이다.^{237) 238)}

그리고 사유신고가 불수리되고 그에 덧붙여 제3채무자가 공탁금을 반환하는 절차까지 필요한 경우 제3채무자는 법원사무관등으로부터 교부 받은 불수리증명서 및 반환받은 공탁서를 공탁소에 제출하여 공탁금의 반환청구를 할 수 있을 것이고, 그 후 다시 그 기재 내용 등을 적법·적정한 것으로 한 다음 다시 공탁해야만 채무를 면할 수 있다(물론, 공탁하지 않고 압류채권자의 추심청구에 응하여 지급하는 것도 가능하다).

236) 대법원 2016. 9. 28. 선고 2016다205915 판결. 이러한 법리는 채권자대위소송에 의하여 집행권원을 얻은 경우에도 동일하게 적용된다. 즉 채권자가 자기의 금전채권을 보전하기 위하여 채무자의 금전채권을 대위행사하는 경우 제3채무자로 하여금 채무자에게 그 지급의무를 이행하도록 청구할 수도 있지만, 직접 대위채권자 자신에게 이행하도록 청구할 수도 있는데(대법원 2005. 4. 15. 선고 2004다70024 판결 등 참조), 채권자대위소송에서 제3채무자로 하여금 직접 대위채권자에게 금전의 지급을 명하는 판결이 확정되더라도, 대위의 목적인 권리, 즉 채무자의 제3채무자에 대한 피대위채권이 그 판결의 집행채권으로서 존재하는 것이고 대위채권자는 채무자를 대위하여 피대위채권에 대한 변제를 수령하게 될 뿐 자신의 채권에 대한 변제로서 수령하게 되는 것이 아니므로(대법원 2015. 7. 23. 선고 2013다30301 판결 참조), 그 피대위채권이 변제 등으로 소멸하기 전이라면 채무자의 다른 채권자는 이에 대하여 압류 또는 가압류, 처분금지가처분을 할 수 있다.

237) 대법원 1999. 1. 8.자 98마363 결정【결정요지】집행법원이 집행공탁금의 배당을 실시하기 전에 공탁자가 집행공탁의 원인이 없음에도 착오로 집행공탁을 한 것임을 이유로 공탁사유신고를 철회한 경우, 그 집행공탁이 원인이 없는 것으로서 무효임이 명백하다면, 집행법원으로서 공탁사유신고를 불수리하는 결정을 할 수 있고, 공탁자는 공탁공무원에게 집행법원의 위 결정을 제출하여 공탁법 제8조 제2항 제2호에 따라 공탁금을 회수할 수 있다.

238) 별지서식 [8-3] 사유신고불수리결정 참조(제8장 말미 수록)

이와 같은 경우는 이미 보았듯이 제3채무자가 공탁금을 반환받을 때에 이전의 공탁에 의한 변제의 효과가 소멸되어버리기 때문에 다시 공탁할 때까지의 지연손해금 등을 부담해야 한다는 불이익이 생길 수 있다.

법원이 사유신고서를 접수한 결과 배당절차에 의할 것이 아니라고 판단될 경우 그 신고서를 불수리(각하)하는 결정을 하는 경우에는 배당절차가 개시되는 것이 아니므로 그 사유신고에는 새로운 권리자의 배당가입을 차단하는 효력이 없다.²³⁹⁾

IV. 사유신고의 정정(또는 보완)

1. 의의

실무상 집행법원은 채권압류명령 또는 가압류명령 등의 사건기록을 검토함으로써 채권의 동일성, 경합하는 압류명령의 내용 등을 확인하는 경우도 있으나, 기본적으로는 대부분이 제3채무자가 제출한 사유신고 및 공탁서의 내용에 의해서 배당재단과 배당등을 받아야 하는 채권자의 범위를 확정하게 된다.

따라서 사유신고서의 기재가 그 실제관계와 다른 경우에는 집행법원이 수리한 후에도 이를 보완·정정할 필요가 있게 된다.

2. 정정의 인정요건

가. 사유신고서의 정정에 관하여는, 공탁서정정의 경우와 달리 그 범위를 확정하는 근거법규는 특히 없다.

그러나 사유신고가 공탁서와 함께 집행법원에 배당재단의 존재 및 배당을 받을 채권자의 범위를 명확하게 하는 것이기 때문에, 제3채무자는 일단 제출된 사유신고에 잘못이 있다고 생각되면, 이것을 정정해야 할 필요가 있고, 집행법원도 제3채무자의 정정신청을 거절할 이유가 없다.

나. 앞서 본 바와 같이 공탁서의 정정은, 공탁실무상 허용범위가 동일성이 인정되는 한도로 상당히 제한되어 있다.

사유신고서의 정정에 있어서도 이러한 ‘동일성’이라는 제한은 어느 정도 필요한 것이지만, 공탁의 성질이 크게 다르지 않고 배당을 받을 채권자의 범위, 공탁금액에

239) 대법원 2005. 5. 13. 선고 2005다1766 판결. 다만 그렇더라도 이 경우 공탁 자체의 효력에는 영향이 없다.

변화가 없고, 공탁서 내용과 실질적 차이가 없는 경우라면 설사 공탁서정정에 있어서는 허용되지 않았던 사안이더라도 사유신고서에 있어는 그 정정을 허용하고, 제3채무자가 이와 같이 제출한 사유신고서에 기재된 모든 사실을 전제로 하여, 배당등 절차를 실시해야 하는 등 그 동일성의 범위를 다소 유연하게 해석할 필요가 있다.

예컨대, 제3채무자가 피압류채권 1,000만 원을 모두 공탁한 후에 공탁서에는 1,000만 원이라고 맞게 기재하였으나, 사유신고서에는 잘못하여 100만 원이라고 기재해버린 경우일지라도 공탁서 등 다른 자료에 의해 그것이 증명되면 이를 정정할 수 있을 것이다.

다. 그런데 이와 같이 공탁서의 기재가 바르고 사유신고서의 기재가 잘못되어 있는 경우에는 위와 같이 사유신고서를 정정시킬 필요가 있지만, 제3채무자에게 연락 등이 되지 않아 사유신고서 정정이 어려운 경우에 어느 쪽 사실을 전제로 배당절차를 실시해야 하는가의 문제가 있다.

살피건대, 이 경우에는 공탁서에 바른 사실관계가 명확히 기재되어 있는 이상, 그 사실을 전제로 배당을 실시해야 하고, 그러한 사유신고서 기재의 잘못이 배당등 절차 실시에 있어서 장애로는 되지 않는다고 보아야 할 것이다.

라. 실무상, 사유신고의 정정이 허용될 수 있는 경우의 예로는, ① 압류사건번호, 당사자의 표시 등의 오기 ② 경합하는 압류명령의 탈루(脫漏) ③ 법령조항의 오기 ④ 공탁일시의 오기 등을 들 수 있겠다.

마. 다만 여기에서 한 가지 더 의문이 드는 것은 위와 같이 사유신고의 정정이 있는 경우에 배당요구의 종기를 언제로 보아야 할 것인가의 문제이다.

이에 대해서는 당해 정정서가 제출된 때라고 보는 견해도 있을 수 있으나, 원래의 사유신고와 그 정정서 사이에 동일성이 인정된다고 보아야 되는 것이고, 또한 만약 정정서 제출시라고 본다면 제3채무자와 어느 채권자 사이에서 이를 이용할 수도 있으며, 채권자 확정에 있어서도 혼란이 야기될 수 있으므로 배당요구의 종기는 여전히 원래의 사유신고서 제출시라고 보아야 할 것이다.

3. 사유신고 정정의 절차

사유신고서를 수리하기 전에 그 잘못이 발견된 경우에는 제출한 문서를 정정하든 못하고, 별도의 문서에 의해 정정할 필요는 없다.

사유신고서는 공탁서를 첨부하여 제출해야 하기 때문에 집행법원은 수리시에 있

어서 양자의 기재에 불일치가 없는지에 관해 그 기재사항을 비교하여 확인한다.

수리시에 압류명령 등의 사건기록과의 조회는 하지 않고 있다. 집행법원은 사유 신고 수리 후에 압류명령 등의 사건기록을 가져와 배당실시를 위하여 기록을 정사(精査)하는데, 실무상 그 단계에서 사유신고서 등의 잘못이 발견되는 경우도 있고, 또 당사자가 정정을 구해오는 경우도 있다.

이러한 경우, 이미 수리된 서면에 정정을 구하는 것은 타당하지 않기 때문에 실무상은 정정해야 할 내용을 기재한 “사유신고보완서” 또는 “사유신고정정서”라는 표제의 별도의 문서를 제출토록 하고 있다.

또 사유신고서의 정정은, 공탁서 정정과 동일하게 문서의 정정인 이상, 문서작성자가 정정신청을 해야 한다.

만약 제3채무자가 경합하는 압류명령이 있는 것을 공탁서, 사유신고서 어느 것에도 기재하지 않은 경우에, 사유신고서 수리 후 당해 압류명령의 채권자로부터 자기 압류명령의 기재가 누락되어 있지만 공탁 전에 제3채무자에게 그것이 송달되어졌기 때문에 자기는 배당받을 채권자라는 뜻의 신청이 있으면, 동일한 내용의 정정을 제3채무자에게 구하는 것이 원칙이지만, 연락이 안되는 등 제3채무자에 의한 정정이 불가능 또는 곤란한 경우에는 집행법원은 압류채권자의 신청내용에 그러한 자료가 있는가 없는가를 조사한 다음 그러한 자료가 있으면 그 채권자를 배당에 가입시켜야 할 것이다.

4. 사유신고의 철회, 취하 등

사유신고서의 제출은 집행공탁이 된 경우에 제3채무자에게 생기는 의무의 성격을 가지고 있고(단, 민사집행법 제248조 제4항에 의해 사유신고는 제3채무자뿐만 아니라 다른 압류채권자 등 이해관계인도 할 수 있는 것이기 때문에 이를 진정한 성격의 의무라고 보기는 어려운 점이 있기는 하다), 압류명령과 같이 신청이라는 성질은 가지고 있지 않다.

따라서 기본적으로 일단 제출된 사유신고를 철회 혹은 취하한다는 것이 가능하지 않다.

다만 제3채무자의 착오나 오류에 의해 무효한 집행공탁을 하고, 그것이 제3채무자에 있어서도 집행법원에 있어서도 무익한 것이라면, 사유신고의 철회와 집행공탁금의 회수를 인정할 필요가 있다.

따라서 이 경우에는 제3채무자에게 이유를 구체적으로 기재한 서면에 의해서 사유신고서의 불수리를 구하는 신청서를 제출시켜, 이미 사유신고를 수리한 후라면 집행법원이 불수리 결정을 하는 것에 의해서, 그 수리 전이라면 공탁관이 불수리증명을

하는 것에 의해 위와 같은 사유신고의 철회를 인정할 수 있다.²⁴⁰⁾

V. 제3채무자에의 조회 등

1. 의의

집행법원에서는 제3채무자로부터 사유신고서 및 공탁서가 제출되면, 그 사유신고가 적정한 것이고 당해 집행법원에서 수리할 수 있는 것인지 아닌지를 판단하게 된다.

그 판단과정에서 사유신고서나 공탁서의 기재내용에 의문이 있는 경우에는, 원칙적으로 제3채무자에 대하여 전화나 조회서 등의 서면으로 조회²⁴¹⁾한 다음 수리·불수리를 확정시키는 것이 바람직한 실무 운용이 될 것이다.

구체적으로는, 사유신고서 및 공탁서의 기재로부터 직접 ① 배당등 절차를 실시할 수 있는지 여부를 판단하고(예컨대, 혼합공탁사건의 경우에 원칙상 혼합해소문서가 제출되지 않으면 배당등의 절차를 진행할 수 없다), ② 배당재단을 확정시키며(예컨대, 압류된 채권 이외의 채권이 공탁금에 포함된 경우에는 그 부분은 배당재단의 대상이 되지 않을 것이다), ③ 배당등을 받아야 하는 채권자를 확정하는 작업을 행하여 배당기일 등을 지정하게 되는데, 위와 같은 사유신고서나 공탁서의 기재가 불명한 경우가 있어서 제3채무자에게 그 여부 등을 조회할 필요성이 있을 수 있다. 또한 골프회원권이나 주권 등 기타 재산권의 압류의 경우에는 이러한 권리가 매각된 후 집행관이 그 매득금을 제출할 때까지 압류 또는 배당요구 등을 한 채권자가 배당을 받을 채권자가 되는데, 이 경우 집행법원에서는 채권자를 확정시키기 위해서 제3채무자에게 조회할 필요성이 생기게 되는 것이다.

이와 같이 배당등 절차를 진행하는 데 있어서는 제3채무자의 역할이 중요한 것으로 되어 있는 경우가 종종 있는바, 이하에서는 집행법원이 제3채무자에게 조회 등을 할 필요성이 있는 경우에 관하여 정리해 보기로 한다.

2. 제3채무자에 대한 조회 등이 필요한 경우

가. 사유신고서에 형식적인 불비가 있는 경우

1) 앞서 보았듯이 제3채무자가 채권압류명령에 응하여 공탁한 경우에는 집행법원

240) 대법원 1999. 1. 8.자 98마363 결정 참조

241) 별지서식 [8-4] 제3채무자에 대한 사실조회서 참조(제8장 말미 수록)

에 사유신고를 해야 되지만(민집 제248조 제4항), 그 사유신고서는 일정한 요건을 기재한 서면일 필요가 있고, 또한 사유신고서를 제출할 때에는 공탁서를 함께 제출해야 한다(민집규 제172조 제1항, 제2항).

2) 그러나 집행법원에 제출된 사유신고서 등은, 많은 경우 위 요건을 만족시키는 것이지만, 형식적으로 구비되지 못한 것 또한 있을 수 있는바, 실무상 나타날 수 있는 예를 들어보면, ① 사유신고서만 제출하고, 공탁서를 첨부하지 않은 경우 ② 사유신고서에 공탁서원본이 아닌 사본을 첨부하여 제출한 경우 ③ 사유신고서를 제출하지 않고 공탁서만 제출한 경우 ④ 사유신고서를 제출하지 않고 공탁서원본이 아닌 사본만을 제출한 경우 ⑤ 공탁을 하지 않았는데도 불구하고 사유신고서를 제출한 경우 ⑥ 변제공탁인데도 불구하고 사유신고서와 공탁서를 제출한 경우 ⑦ 별지로 된 「공탁원인인 사실」란을 빠뜨린 채 공탁서만을 사유신고서에 첨부하여 제출한 경우 등을 생각해볼 수 있겠다.

3) 앞서 본 바 대로 사유신고서와 공탁서는 배당재단과 채권자의 확정에 필요한 요건이므로 위 ①②③④와 같은 경우에는 집행법원에서 전화 등으로 제3채무자에게 제출을 촉구하거나 제출 유무를 조회하는 것이 필요하다(공탁서사본만 제출한 경우에도 그 원본을 제출케 하여 기록에 첨부하여야 할 것이다).

만일 제3채무자에 대한 제출촉구가 어려워 보정이 되지 않는다면 위 ①②의 경우는 사유신고를 불수리해야 할 것이며, ③④의 경우는 소위 잠재적인 집행공탁사건이라 할 것인데, 이때는 애써서 제3채무자가 공탁해도 집행절차에 반영되지 않고 채권자측에서도 채권회수가 완성되지 않는 이른바 무효한 공탁이 될 수도 있는 것이다.

그리고 ⑦의 경우는 공탁서의 「공탁원인인 사실」란에 관하여 기재사항이 많은 것 때문에 이를 별지로 할 때에 발생하는데, 이때는 공탁관이 간인한 공탁서와 별지 부분이 전체가 일체로서 공탁서원본을 구성하므로 그 별지부분을 제외한 채 공탁서를 제출하면 이를 제출하지 않은 것으로 될 수 있다. 따라서 이 경우도 제3채무자에게 조회할 필요가 있다.

⑤의 경우는, 공탁에 관한 란을 공란으로 해서 사유신고만을 제출하는 경우와 공탁에 관한 란에 채권자에의 지급 사실을 기재하여 사유신고서를 제출하는 형태로 발생할 수 있다. 전자의 경우에는 공탁에 관한 부분에 대하여 기재를 누락하였는지, 아니면 당초 공탁을 하지 않은 것인지 확실하지 않게 되어 어느 경우든 조회가 필요하다. 후자의 경우에도 사유신고서를 제출하는 전제로서 공탁을 하였는지 여부에 관

한 조회 등을 하는 것이 좋다. 어느 경우이든 공탁을 하지 않은 때에는 사유신고서를 제출한 것으로 해서는 안 된다.

⑥에 대해서도 제3채무자의 보정이 어려우면 사유신고서를 불수리해야 할 것이다.

나. 사유신고서에 실질적인 불비가 있는 경우

이는 사유신고서의 기재 내용과 공탁서의 공탁원인인 사실의 기재 내용에 불일치가 있는 경우 또는 공탁서의 기재내용과 채권압류명령에서 압류된 채권이 동일한 것인지 여부가 확실하지 않은 경우와 같이, 그 기재 내용에 관하여 의문 등이 있는 경우에는 제3채무자에의 조회를 할 필요가 있다. 예컨대, 임료채권을 압류한 경우에 공탁금이 채권압류명령에서 대상으로 한 임대차에 근거한 임료인가에 대해 조회를 하는 경우이다.

이와 같은 경우의 조회는 사유신고서를 수리할 것인가 아니면 불수리할 것인가 혹은 배당재단으로 되는 범위의 문제와 직접 관계되는 중요한 조회인 경우가 많으므로 통상은 서면으로 조회를 하고, 서면에 의해 회답을 구하는 것이 좋으리라고 본다.

다. 그 밖에 조회가 필요한 경우

다음과 같은 경우에는 제3채무자측으로부터 어떠한 불비(不備)가 있다고 말할 수는 없지만, 배당등 절차의 진행상 제3채무자에게 조회할 필요가 있을 수 있다.

1) 첫째로, 계속적인 급부를 목적으로 하는 채권이 압류된 때에 압류채권액 전액의 공탁이 모두 이루어지기 전인데도 불구하고 제3채무자가 사유신고서 등을 제출하지 않는 경우를 들 수 있다.

이 경우 그 내부적 원인으로는 예를 들어 급료채권에 있어서 채무자의 퇴직이나 파산, 임료채권에 있어서 제3채무자의 임차물건으로부터의 퇴거 또는 경매에 의한 임차물건의 매각 등을 생각해볼 수 있으나, 집행법원으로서의 그 사정을 알 수 없기 때문에 후행 절차의 진행을 위해 제3채무자에게 그 이후의 공탁 유무 등에 관하여 조회할 필요성이 있는 것이다. 특히, 이러한 조회는 채권압류명령의 효력으로부터 해방되었다고 생각하고 있는 제3채무자에게 매우 번잡스러울 것이므로 이 경우는 그 조회 후 내용을 공탁서 또는 사유신고서의 여백 등에 기재해 놓는 것이 좋을 것이다.

이러한 기재가 있으면, 집행법원으로서도 그때까지의 공탁분을 신속하게 배당하고, 압류채권자에 대하여 압류명령의 취하를 검토하도록 촉구하는 조치를 하는 것이 가능해진다.

2) 둘째로, 공탁금이 적기 때문에 그대로는 배당등의 절차를 진행할 수 없는 경우, 즉 은행예금에 있어서 최초의 보통예금분이 아주 적어서 그것이 절차비용에도 미치지 못하는 경우에는, 그렇다 하더라도 이후에 정기예금이 만기에 이르러서 공탁되는 사례도 있기 때문에 최초 공탁시점에서 제3채무자에게 이후의 공탁 가능 유무 등에 관하여 조회해 보는 것이 바람직하다.

3) 셋째로, 민사집행법 제236조 제2항에 따라 추심채권자가 공탁하고 사유신고를 한 경우나 민사집행법 제248조 제4항 단서에 의해 제3채무자가 아닌 압류채권자 등 다른 이해관계인이 사유신고를 한 경우 등에 있어서는 사유신고서의 기재 등이 미흡한 때 제3채무자에게 압류된 채권에 대하여 채권의 존부, 변제의사의 유무, 우선하는 권리 존재 여부, 다른 압류명령이나 가압류명령 등을 송달받은 사실이 있는지 여부 등을 조회할 필요가 있다(민집규 제184조 제1항).²⁴²⁾ ²⁴³⁾

3. 사유신고서 등에 대신한 조회

채권배당절차는 사유신고서 및 공탁서가 집행법원에 제출되어 배당등의 절차가 실시되는 경우가 많지만, 예를 들면 골프회원권, 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권 그 밖의 재산권을 현금화한 경우 그 매각대금의 배당절차나 유가증권의 매각대금의 배당등 절차 또는 동산인도청구권의 압류에 근거한 환가대금의 배당절차의 경우에는 사유신고서나 공탁서가 제출되지 않고 배당절차가 실시된다.

이와 같이 사유신고서 등이 제출되지 않고서 배당등의 절차가 진행되는 경우에는 배당을 받아야 하는 채권자를 어떻게 확정할 것인가 하는 문제가 생긴다.

이미 말한 바와 같이 이러한 경우는 집행관이 집행법원에 매각대금을 제출할 때까지 압류 등을 한 채권자가 배당을 받아야 하는 채권자로 된다고 정해져 있다(민집 제247조 제1항 제3호).

그런데 집행법원에서는 매각의 기초가 된 사건 및 집행관이 매각대금을 제출한 때를 인식하는 것은 가능하지만, 그 이전에 다른 압류 등이 있는지 여부에 관해서는 인식할 수가 없다. 그리고 압류 등의 유무에 관해 무엇보다도 확실하게 인식하고 있는 것이 제3채무자일 것이다.

그래서, 집행법원이 배당을 받아야 하는 채권자를 확정하기 위해서 제3채무자에게 조회를 할 필요성이 생기는 것이다. 이 조회에 대한 회답서는 위에서 본 사유신고

242) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 501-503.

243) 별지서식 [8-4] 제3채무자에 대한 사실조회서(제8장 말미 수록)

서의 제출에 대신하는 것이라고 말할 수 있고 또한 매우 중요한 것이다.

4. 집행법원의 조회에 대한 제3채무자의 책임

집행법원으로부터 행해지는 위와 같은 조회에 대해서는 제3채무자측이 그것에 대해 회답해야 하는 법률적인 의미에서의 의무가 있는 것은 아니다.

그러나 위 조회는 배당등 절차의 진행상 반드시 필요한 경우에 행해지고, 또 그 회답은 그 중요성이 높은 것이 많다. 특히, 사유신고서의 제출에 대신하는 조회에 있어서는 회답이 없으면 다른 절차를 진행할 방법이 없다. 따라서 제3채무자로서도 그 중요성을 이해하고, 배당등의 절차가 진행되지 않아 자신이 행한 공탁이 헛되이 되지 않기 위해서도 이에 대해 적극적으로 협력해야 할 필요성이 있다고 보아야 할 것이다.

제5절 착오를 이유로 한 집행공탁금의 회수

I. 공탁의 무효와 공탁금의 회수

공탁은, 법률행위의 일종으로서 그 유효요건을 구비하지 않으면 효력이 생기지 않는다. 집행공탁의 경우, 압류의 유효성 등의 공탁원인이 존재하는 등이 그 요건으로 된다. 그리고 유효무효는 최종적으로는 소송절차에 의해서 확정된다.

그런데 공탁자는 통상 대부분 공탁절차에 정통하지 않고, 또 공탁시에 잘못 생각하여 무효인 공탁을 하는 경우가 있다. 그리고 이러한 공탁을 한 경우에 채권소멸이라는 실제적인 효과가 생기지 않음에도 불구하고 공탁금을 회수하여 다시 공탁할 수 없다고 한다면 불합리하다. 그래서 공탁절차상 일정한 경우에는 공탁금의 회수를 인정할 필요가 있게 된다.

채권집행에 있어서 제3채무자의 집행공탁도 공탁의 한 유형인 이상 공탁금의 회수에 관하여 일반공탁과 동일하다고 여겨질 수가 있다. 그러나 제3채무자의 집행공탁에 있어서는 그 공탁금의 관리를 집행법원이 행하고 당사자의 의사표시에 의해 공탁금의 귀추가 정해지는 것은 아니므로 집행법원이 바로 권리관계를 파악할 수 있는 경우에는 공탁금의 회수에 의한 재공탁을 제3채무자에게 강요하지 않아도 배당등 절차를 실시할 수 있는 경우가 있을 수도 있다.

여기서는 우리의 현행법상 제3채무자의 집행공탁에 있어서 회수를 인정할 수 있는지 여부 및 인정할 경우 그 절차 등에 관하여 검토하기로 한다.

II. 공탁금 회수의 요건과 일반적 절차

1. 회수의 근거 및 일반절차

공탁금의 회수란, 공탁자(또는 그 승계인)가 공탁 본래의 목적을 달성하지 못하고 공탁금의 지급을 청구하는 것을 말한다.

변제공탁의 경우는 공탁요건의 결여로 공탁이 공탁법상 부적법하여 무효인 경우 뿐만 아니라 유효한 공탁인 경우에도 공탁자가 회수할 수 있다(민법 제489조 참조

).²⁴⁴⁾ 집행공탁의 경우에는 그 인정 여부에 관하여 논의가 있을 수 있다.²⁴⁵⁾

착오 그 밖의 무효를 이유로 공탁금을 회수하는 경우에는 공탁금출급청구서에 공탁이 무효인 것을 증명하는 서면 또는 착오사실을 증명하는 서면을 첨부해야 한다.²⁴⁶⁾

착오를 증명하는 서면은, 이것에 의해 공탁관이 착오를 인정할 수 있는 서면일 필요가 있지만, 구체적인 경우에 의해서 그 서면은 똑같지는 않다. 단순히 공탁자가 작성한 이유서로는 족하지 않다. 다만 공탁관에게 공탁서의 기재로부터 착오인 것이 명확한 경우에는 착오를 증명하는 서면이 필요하지 않으며, 또한 이는 당해 공탁이 무효인 것의 확정판결이나 관공서가 작성한 서면에 한하지 않고, 사서증서인 때에도 이에 신빙성이 있으면 착오를 증명하는 서면에 해당할 수 있다.

2. 착오로 인한 집행공탁금의 회수

가. 집행공탁금의 성질과 회수청구권 인정 여부

채권집행에 있어서 집행공탁은, 압류된 채권을 제3채무자가 공탁하는 것에 의해 채무자에 대하여 면책을 주장하는 것이고, 그 공탁금은 압류채권자에 대한 관계에서 배당재단으로 되는 것이다.

이와 같이 집행공탁에 의해 그 공탁금의 관리는 집행법원으로 이행되고, 배당등 절차에 따라 지급위탁에 의해서만 공탁금이 지급되게 된다. 따라서 이러한 집행공탁에서는 변제공탁과 달리 원칙적으로 공탁자는 그 공탁금을 다시 회수할 권리를 갖지 않는다.²⁴⁷⁾

그러나 이것은 유효한 집행공탁이 되는 것을 전제로 하는 경우이고, 예컨대 공탁원인이 없는데도 공탁이 된 경우 등으로 공탁이 무효임이 명백한 경우에는 집행공탁에 있어서도 일정한 이유를 원인으로 하는 공탁금의 회수를 인정할 필요가 있다고 보아야 할 것이다(공탁법 제8조 제2항 제2호 참조).²⁴⁸⁾

대법원 1999. 1. 8.자 98마363 결정도, “집행법원이 집행공탁금의 배당을 실시

244) 공탁규칙 제32조 이하; 김인수(주211), 75.; 법정질의회답(1991. 4. 9. 제637호)

245) 일본의 경우도, 집행공탁에 있어서 공탁법 제8조 제2항에 의해 착오 그 밖의 공탁의 무효를 이유로 한 공탁금의 회수를 인정하고 있다.

246) 법정질의회답(1991. 4. 9. 제637호)

247) 김인수(주211), 183.

248) 同旨; 김인수(주211), 183.

하기 전에 공탁자가 집행공탁의 원인이 없음에도 착오로 집행공탁을 한 것임을 이유로 공탁사유신고를 철회한 경우, 그 집행공탁이 원인이 없는 것으로서 무효임이 명백하다면, 집행법원으로서도 공탁사유신고를 불수리하는 결정을 할 수 있고, 공탁자는 공탁관에게 집행법원의 위 결정을 제출하여 공탁법 제8조 제2항 제2호에 따라 공탁금을 회수할 수 있다.”라고 판시하여 이를 인정하는 취지이다.

나. 실무상 착오가 생기는 구체적인 사례

1) 공탁소 관할위배의 경우

집행공탁은 채권자 또는 채무자의 보통재판적 소재지의 집행법원에 하여야 하는 데도(민집 제19조), 그와 다른 공탁소에 공탁을 하는 경우가 있을 수 있다.

변제공탁의 경우에는, 이러한 경우 피공탁자가 공탁을 수락하고 또는 공탁금의 출급청구를 할 때까지는 착오를 이유로 하여 회수청구를 하는 것이 가능하다고 보지만(민법 제489조), 집행공탁에 있어서는 피공탁자가 없고 지급위탁 등에 의하지 않는 공탁금의 출급청구는 인정되지 않기 때문에 관할이 위배된 경우 배당절차를 실시하기 전이라면 제3채무자가 공탁금을 회수할 수 있다고 보아야 할 것이다.

다만 이와 같이 집행공탁이 관할위배인 것에 대해 제3채무자도 그 신청을 하지 않고, 집행법원도 이를 발견하지 못하였으며, 혹은 채무자 또한 집행법원의 사유신고의 수리에 대해 이의의 신청을 하지 않는 경우 등에 있어서는 그대로 배당절차가 진행되어 버리는 예도 있을 수 있으나, 이 경우도 당해 공탁에 의해 배당등 절차가 실시되는 것이 사전에 채무자에게 통지된 이상 어쩔 수 없는 일이라고 말할 수 있다.

집행공탁이 관할위배인 경우 제3채무자가 공탁금의 회수를 하는 때에는 집행법원에 대하여 당해 공탁이 관할위배인 것을 이유로 한 사유신고불수리증명 또는 불수리결정을 구하여 이를 나타내는 서면을 착오를 증명하는 문서로서 공탁소에 제출하여 공탁금의 회수청구를 하면 될 것이다.

2) 공탁의무가 실제로 생기지 않는 경우

공탁원인이 없이, 집행공탁을 해야 되는 경우가 아님에 불구하고, 집행공탁을 한 경우 그 공탁은 무효이다. 공탁원인인 사실이 없는 경우로서 다음과 같은 경우를 생각해 볼 수 있다.

가) 압류명령이 공탁 전에 실효되어 있었던 경우

제3채무자가 집행공탁을 하기 직전에 압류명령이 취하, 취소되어 실효하였지만, 이것이 통지되기 전에 제3채무자가 공탁한 경우가 있을 수 있다. 이 경우에는 공탁원

인이 없기 때문에 공탁은 무효이고, 제3채무자는 착오를 이유로 한 공탁금의 회수를 청구할 수 있다.²⁴⁹⁾

이 경우 실질적으로는 변제공탁이 된 것으로 보아 집행법원이 채무자에게 지급 위탁을 하면 족하고 제3채무자가 공탁금의 회수를 한 다음에 변제할 것까지는 없다는 견해도 있을 수 있으나, 공탁시에 원인이 소멸되어 있는 집행공탁을 그대로 변제공탁으로 보는 것은 문제가 있고 이 무효인 공탁 후에 그 채권을 압류채권으로 하는 압류 명령의 송달이 있었던 경우, 후자의 압류명령의 채권자와의 관계에서도 문제가 생길 여지가 있으므로 집행법원이 위와 같이 채무자에게 지급위탁을 하는 것은 상당하지 않다고 본다.

나) 의무공탁을 해야 하는데, 권리공탁을 하는 등 집행공탁인 것에는 변화가 없지만, 그 전제사실(법령조항을 포함)이 틀린 경우

이 경우 공탁서의 정정에 의해 바로 기재를 변경하면 문제가 없지만, 공탁서의 동일성이 없게 되어 공탁관이 정정을 불가하다고 판단한 경우에는 공탁금의 회수에 의해 재공탁을 인정할 필요가 있다.

이 경우는 곧바로 권리관계를 증명하는 문서를 착오를 증명하는 문서로서 제출하고 공탁금의 회수를 구하면 될 것이다.

이 경우 회수의 가부(可否)도 공탁관의 판단에 맡겨지게 된다. 또 제3채무자는 집행법원에 대해 착오에 의한 공탁인 것을 신청하고, 사유신고의 불수리증명 혹은 불수리결정을 얻어 이것을 공탁소에 제출하는 방법으로 공탁금의 회수를 하는 것도 생각해볼 수 있다.

또 공탁서 등의 정정 또는 재공탁이 없는 경우에도 집행법원이 사유신고서의 정정을 인정하고, 공탁의 잘못이 없는 것으로 보아 그 권리관계를 전제로 배당절차를

249) 대법원 1999. 1. 8.자 98마363 결정【결정요지】[1] 제2차 납세의무자 소유의 부동산에 대한 임의경매절차에서 세무서장이 국세에 대한 교부청구를 하여 이를 교부받았는데 그 후 국세의 부과처분이 확정판결에 의하여 취소된 경우에는 교부받은 국세 상당액은 교부청구가 없었더라면 경매절차에서 채권의 우선순위에 따라 배당을 받았을 후순위 채권자들에게 반환되어야 하고, 그 후순위 채권자들의 채권이 이미 소멸되었다거나 그 채권을 변제하고도 잉여가 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 경매 목적 부동산의 소유자인 제2차 납세의무자나 원래의 납세의무자에게 반환될 성질의 것이 아니다. [2] 집행법원이 집행공탁금의 배당을 실시하기 전에 공탁자가 집행공탁의 원인이 없음에도 착오로 집행공탁을 한 것임을 이유로 공탁사유신고를 철회한 경우, 그 집행공탁이 원인이 없는 것으로서 무효임이 명백하다면, 집행법원으로는 공탁사유신고를 불수리하는 결정을 할 수 있고, 공탁자는 공탁공무원에게 집행법원의 위 결정을 제출하여 공탁법 제8조 제2항 제2호에 따라 공탁금을 회수할 수 있다.

진행하는 경우도 있을 것이다.

다) 우선하는 전부명령이 효력이 생기고 있는데도 압류경합으로서 집행공탁을 한 경우

압류 및 전부명령이 송달된 후에 그 압류채권에 대한 별개의 압류명령이 송달되었지만, 최초 전부명령이 확정된 경우에는 그 채권이전의 효력은 제3채무자에게 전부명령이 송달된 때에 생기기 때문에 후에 송달된 압류명령은 효력이 없게 된다.

따라서 전부명령이 확정된 후에는 집행공탁은 공탁원인이 없어서 허용되지 않고 그 전부채권자를 피공탁자로 하는 변제공탁만이 허용된다. 그런데도 이 경우 제3채무자가 집행공탁을 한 때는 집행법원이 착오를 이유로 사유신고에 대한 불수리결정을 하게 될 것이다.

다만 실제상 제3채무자에게는 전부명령의 확정이 명확하지 않으므로 그 후의 압류명령과의 경합을 이유로 하는 집행공탁을 하는 경우가 있고,²⁵⁰⁾ 공탁실무도 전부명령의 확정이 명확하지 않은 경우에는 이러한 집행공탁의 수리를 허용하고 있는 것으로 보인다.

또한 위 공탁이 전부명령의 확정 후에 된 경우에 있어서도 전부명령의 채권자는 집행공탁에 의한 배당등 절차사건의 당사자이고 그 채권자에게 공탁금의 지급위탁을 하는 것은 가능하기 때문에, 제3채무자가 공탁금을 회수하여 전부채권자에게 지급할 것 없이, 집행법원이 지급위탁절차에 의해 전부채권자에게 지급할 수도 있을 것이다.

라) 우선하는 유효한 채권양도의 통지가 있음에도 이것을 간과하여 그 후에 송달된 압류명령을 근거로 집행공탁을 한 경우

채권양도는 공시되지 않기 때문에 유효하게 채권양도가 된 후에 그 채권에 대하여 다시 압류명령이 발령될 수도 있다.

이 경우 제3채무자에 대하여 확정일자 있는 양도통지가 된 경우는 양수인은 압류명령의 채권자에 대해 위 양도행위로서 대항할 수 있고, 결과적으로 위 압류명령은 효력이 없게 될 것이다.

이와 같이 채권양도가 유효한 한, 압류명령은 효력이 없는 것으로 되므로 집행

250) 앞서 본 바 있듯이 대법원 1996. 6. 14. 선고 96다5179 판결의 취지를 감안하면, 이러한 경우에도 제3채무자의 입장에서 그 우선순위의 판단 등에 문제가 있는 사유가 있다고도 볼 수 있기 때문에 그에 따른 제3채무자의 집행공탁을 인정할 여지가 있고, 실무는 이 경우 배당절차에 의해서 사건을 종료하는 경우도 자주 있다.

공탁의 원인 없이 채권양도의 존재를 간과하여 한 집행공탁도 무효로 된다. 따라서 이와 같이 제3채무자가 착오에 기초하여 집행공탁한 경우에는 공탁금의 회수를 인정할 필요가 있다.

이 경우 착오를 증명하는 것으로서 공탁소에 제출하는 서면으로서는 집행법원이 공탁원인이 없음을 이유로 교부해준 사유신고불수리결정정보 또는 불수리증명서가 이에 해당하는 것임은 문제가 없다.

문제는 집행법원에 어떠한 서면을 제출한 경우에 사유신고불수리결정 등을 받을 수 있는가에 관한 것이다. 공탁이 무효인 것을 확인한 확정판결은 착오를 증명하는 문서에 해당한다. 예컨대, 제3채무자가 채무자에 대하여 채무부존재확인의 소송, 압류채권자에 대하여 채권양도가 우선하고 있는 것에 의한 공탁금회수청구권 확인의 소를 제기한 경우 내려진 승소판결이 여기서 생각될 수 있다. 이때 단순히 이러한 문서를 공탁소에 제시하는 것만으로는 집행법원이 알지 못하는 사이에 공탁금 회수를 인정하는 것으로 되기 때문에 제3채무자는 이런 문서를 집행법원에 제출하여 공탁이 무효인 것을 증명함으로써 사유신고불수리결정(혹은 공탁금을 제3채무자에게 교부한다는 뜻의 결정)을 얻은 다음 그러한 모든 문서를 공탁소에 제출해야 된다고 본다. 집행공탁의 원인이 된 모든 압류채권자의 공탁금 회수에 대한 동의서는 위와 같은 착오를 증명하는 문서에는 해당하지 않지만, 그것을 제출한 경우에도 공탁금의 제3채무자에 대한 교부를 인정할 여지는 있을 것이다.

착오에 의한 공탁인가 아닌가가 위와 같은 판결 등으로 증명되지 않으면 집행법원으로서서는 그대로 배당등 절차를 진행해야 할 것이다.

이러한 사태는 채권양도가 우선하는 경우에 한하지 않고, 양도의 유효무효가 명확하지 않아 혼합공탁을 해야 함에도 이것을 간과하여 단순히 집행공탁만을 한 경우에도 발생한다. 이 경우도 제3채무자가 공탁이 무효인 것을 판결 등으로 증명한 경우에는 집행법원은 공탁금을 제3채무자에게 교부해줄 수 있을 것이다.

3. 착오를 증명하는 서면

가. 채권압류명령의 취하증명서

집행공탁은 채권압류명령의 존재를 원인으로 하므로 집행공탁 전에 이 채권압류명령이 실효한 경우에는 공탁시에 공탁원인이 없는 것으로 되기 때문에 공탁은 무효로 되고, 이때에는 그 실효를 증명하는 것에 의해 공탁금회수를 할 수 있다(공탁 후

에 압류명령의 취하가 있는 경우에는 이를 배당금수령권의 포기로 보아 집행법원이 채무자에 대하여 지급위탁을 하는 방식을 취하는 것이 실무의 취급례이다).

따라서 집행공탁의 원인이 된 모든 압류명령의 취하가 있었음을 증명하는 문서(일반적으로, 집행법원 소속 법원사무관등이 발행하는 취하증명서 또는 취하통지서)는 착오를 증명하는 서면에 해당한다.

다만 제3채무자가 사유신고를 집행법원에 제출한 경우에는 이것을 원인으로 한 배당등 절차사건이 접수되어 있기 때문에 공탁금을 회수하기 위해서는 단순히 취하증명이 된 것을 현출하는 것만으로는 부족하고, 집행법원에 당해 사유신고를 불수리한 것을 증명하는 서면을 필요로 하는 경우가 있을 것이다.

나. 사유신고불수리증명서

집행법원이 사유신고를 수리하기 전에 제3채무자가 착오를 이유로 공탁금의 회수를 함에는 사유신고를 수리해야하는 집행법원에 당해 사유신고서를 수리하지 않은 증명신청을 하고, 이것이 인정된 증명서가 발행된 경우에는 당해 사유신고불수리증명서는 착오를 증명하는 서면에 해당한다.

이 불수리증명신청은 공탁서를 특정하고, 집행법원이 사유신고를 불수리로 해야 하는 구체적인 사유를 상세히 기재한 다음 집행법원이 당해 사유신고를 수리하지 않았다는 것의 증명을 집행법원의 법원사무관등에게 구하는 형식으로 한다.²⁵¹⁾

다. 사유신고불수리결정정보

집행법원이 사유신고를 수리한 후에 착오나 오류에 의한 집행공탁의 무효를 발견한 경우 혹은 제3채무자의 신청 등에 의해 공탁의 무효를 알게 된 경우에는 실제 관계를 중시하여 당해 사유신고를 불수리하는 결정을 할 수가 있다.²⁵²⁾

이 경우는 이 불수리결정정보를 제3채무자에게 교부하여야 하고, 이 결정정보는 착오를 증명하는 서면으로 된다(실무상 결정정보를 공탁소에 직접 송부하는 방법도 생각할 수 있으며, 그럴 경우에는 착오가 공탁소에 명확하게 되므로 착오를 증명하는 서면은 불필요하게 될 것이다).

이 불수리결정에는 공탁서의 특정과 함께, 당해 사유신고를 불수리로 하는 구체적인 사유가 이유 중에 기재되기 때문에, 이 기재에 의해 공탁자의 착오의 내용을 공

251) 별지서식 [8-2] 사유신고불수리증명신청 참조(제8장 말미 수록)

252) 별지서식 [8-3] 사유신고불수리결정 참조(제8장 말미 수록)

탁소가 알게 된다.

라. 집행공탁을 무효로 선언하는 판결정본과 확정증명서

공탁의 유효 또는 무효를 선언하는 판결이 어떠한 형태로 되어야 할 것인가에 관하여는 문제가 있지만, 일단 공탁을 무효로 하는 판결이 확정된 경우에는 당해 공탁금을 유지할 필요가 없게 되므로 이것을 증명하는 문서는 착오를 증명하는 서면에 해당한다.

다만 집행공탁에 있어서는 당해 공탁에 기초한 사유신고서가 제출되어 있는 경우, 그것을 원인으로 하는 배당절차사건의 처리가 문제로 된다. 일반적으로 이 무효를 선언하는 판결정본과 확정증명서를 집행법원에 제출하고 집행법원이 공탁무효를 이유로 사유신고불수리결정을 하는 것으로 하면 될 것이다. 집행공탁의 경우에 사유신고불수리결정 등의 제출 없이 무효를 선언하는 판결정본과 확정증명서만으로 착오가 증명된 것으로 보아 공탁소가 공탁금의 회수를 인정하는 것은 집행법원이 알지 못하는 사이에 공탁금의 회수를 인정하는 것이 되어 타당하지 않다고 생각한다.

4. 회수에 의한 실체법상, 절차상 효과

집행공탁도 채무자에 대한 한도에는 일종의 변제공탁의 성질을 가지고 있으므로 공탁으로 채권소멸의 효과를 발생시킨다(민법 제487조).

따라서 제3채무자가 이 공탁금을 회수한 경우에는 일단 발생한 위와 같은 채권소멸의 효과가 소급적으로 실효하고 처음부터 채무를 부담하고 있었던 것으로 된다.

민사집행법 제252조에 의하면 집행공탁시까지 제3채무자에 송달된 압류명령 등의 채권자가 당해 배당절차에서 배당을 받을 채권자로 되는 것이어서²⁵³⁾ 집행공탁에 의해 배당가입에 대한 차단효과 발생하게 되는데, 제3채무자가 이 공탁금을 회수한 경우에는 일단 발생한 위와 같은 배당가입차단효는 소급적으로 소멸하고, 배당요구의 종기 등은 도래하지 않은 것으로 된다.

253) 앞의 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 422.

제6절 추심채권자의 공탁

(민집 제236조 제1항, 제2항)

I. 추심신고의무(민집 제236조 제1항)

1. 추심채권자가 채권을 추심한 때에는 추심한 채권액을 법원에 신고하여야 한다(민집 제236조 제1항).

추심신고는 사건의 표시, 채권자·채무자와 제3채무자의 표시,²⁵⁴⁾ 제3채무자로부터 지급받은 금액과 날짜를 적은 서면으로 한다(민집규 제162조 제1항).

이는 추심명령에 의한 채권의 추심은 집행채권자가 스스로 추심을 하기 때문에 추심이 제대로 되었는지 여부를 알 길이 없으므로 채권자가 제3채무자로부터 추심을 마친 때에는 그 사유를 집행법원에 신고하도록 한 것이다.²⁵⁵⁾

2. 이 신고의무는 제3채무자가 임의로 변제한 경우이건 채권자가 추심소송 또는 강제집행 등 재판상의 권리를 행사하여 취득한 경우이건 이를 묻지 않고 채권자에게 인정되는 것이다.²⁵⁶⁾

또한 위 의무는 추심명령의 대상인 채권의 일부만이 추심된 경우에도 발생하며, 계속적 법률관계에 기초하여 발생하는 채권이 압류된 경우에는 추심신고서에 어느 지급기의 해당액인가를 특정하여 매 추심시마다 신고를 하여야 한다.²⁵⁷⁾

일반의 채권집행에 있어서 압류채권자가 민사집행법 제236조 제1항에 따라 집행법원에 대하여 하는 추심신고는 사건종료의 보고 성격을 가지는 것이지만, 계속적 급부의 압류사건에 있어서는 맨 마지막 1회분의 추심신고만이 일반의 경우와 같은 사건

254) 제3채무자가 복수인 경우(주채무자와 연대채무자)에는 실제 추심에 응한 자만을 제3채무자로 표시한다.

255) 추심의 신고에 관한 민사집행법 제236조 제1항은 독일이나 프랑스에서 연유하지 않는 우리와 일본의 독창적인 것으로서 평등배당주의를 채용하여 배당에 가입한 채권자에게 평등한 배당을 하는 것이 원칙인 우리 법제하에서 달리 경합하는 채권자가 없는 한 이 신고가 있는 범위 내에서 채권집행의 전부 또는 일부의 종료를 가져오게 하는 전제아래 추심채권자에게 절차상의 보고의무를 지운 것이라고 한다. 조관행, “추심명령에 의한 추심에 관한 제문제, 강제집행·임의경매에 관한 제문제(상), 재판자료 제35집, 529.; 宮脇幸彦, 強制執行法(各論), 有斐閣, 148. 등 참조

256) 조관행(주251), 529.

257) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 378.

종료의 보고와 같은 성격을 가지고 그 때까지 행해진 중간의 다른 추심신고는 변제충당의 통지와 같은 성격을 가지고 있는 것이어서 양자의 성질이 약간 다르다고 볼 수 있다.

3. 추심신고에 의하여 달리 채권자가 없는 때에는 추심한 범위 내에서 채무명의의 집행력은 소멸되고 집행절차는 종료한다. 다만 배당요구를 한 다른 채권자가 있는 때에는 배당절차가 종료한 때에 집행절차가 끝난다.²⁵⁸⁾ 따라서 추심신고가 있으면 다른 채권자들에 의한 배당요구는 더 이상 허용되지 않는다(민집 제247조 제1항 제2호).

만일 추심을 하고서도 그 신고를 하지 않고 있으면 다른 채권자의 배당요구를 막지 못하지만, 제3채무자가 변제한 이상 목적채권(피압류채권)은 소멸하므로 추심신고가 있기 전에도 다른 채권자의 (가)압류는 허용되지 않는다. 다만 제3채무자 변제 이후의 (가)압류에 대하여 배당요구로서의 효력을 인정할 것인지에 대하여는 다툼이 있다(제6장 집행의 경합 제2절 V. 1. 다. 참조).

4. 추심신고가 있을 때까지 다른 채권자들의 배당요구가 없으면 추심채권자가 독점적으로 집행채권과 집행비용의 변제를 받고 나머지는 채무자에게 반환하면 된다.

하지만 추심신고를 하지 아니한 때에는 채권자로서는 추심금을 자기 채권의 변제에 충당할 수 없고,²⁵⁹⁾ 다른 채권자들로부터 계속하여 배당요구를 받게 되므로 채권자의 입장에서는 추심신고를 하는 것이 유리하지만, 실제에는 추심신고가 행해지는 경우가 드물고, 추심신고서가 제출될 때까지는 추심명령신청사건이 미제로 처리되므로 실무상 법원의 미제사건 처리가 가장 문제이다.

II. 공탁 및 사유신고의무(민집 제236조 제2항)

1. 채권자가 추심의 신고를 하기 전에 다른 압류, 가압류 또는 배당요구가 있었을 때에는 채권자는 추심한 금액을 바로 공탁하고 그 사유를 신고하여야 한다(민집 제236조 제2항).

여기서 “다른 압류”에는 체납처분에 의한 압류가 포함되고, “다른 배당요구”에는 조세채권자의 교부청구 또는 참가압류가 포함된다.²⁶⁰⁾

258) 이영섭 대표, 주석강제집행법(중), 한국사법행정학회(1985), 90-91.

259) 조관행(주251), 530.

260) 임용모(주101), 758.

2. 사유신고는 사건과 당사자의 표시, 제3채무자로부터 지급받은 금액과 날짜와 공탁사유 및 공탁한 금액을 적은 서면에 공탁서를 붙여서 하여야 한다(민집규 제162조 제2항).

3. 배당요구가 있으면 법원은 그 사실을 채권자에게 통지하여야 한다(민집 제247조, 제219조). 이는 채권자에게 채권자의 경합이 있음을 알려주는 역할을 하는 것이다.

또 추심신고가 있는 경우에 그 전에 채권자가 경합되어 공탁하여야 하는 경우이면 집행법원은 적당한 방법으로 그 사실을 추심채권자에게 알려 주어 공탁 및 사유신고를 하도록 함이 상당하다.

4. 민사집행법 제252조 제2호는 같은 법 제236조에 따라 추심채권자가 공탁한 때에 배당절차가 개시된다고 규정하고 있으나, 추심채권자가 공탁하였더라도 그 사유를 같은 법 제236조 제2항에 따라 집행법원에 신고하지 않는 한 집행법원으로서 그 사실을 알기 어려우므로 실질상 추심채권자가 공탁한 다음 그 사유를 집행법원에 신고하였을 때에 배당절차가 개시된다고 보아야 할 것이다.

5. 또한 압류 등의 경합이 있음에도 불구하고 추심을 완료한 채권자가 공탁의무를 이행하지 않을 경우에 다른 경합채권자는 민사집행법 제236조 제2항을 근거로 하여 추심채권자를 상대로 추심한 금원을 법원에 공탁하고, 그 사유를 신고할 것을 구하는 소를 제기할 수 있다.²⁶¹⁾

이 경우 이를 인용하는 주문의 방식 등에 관하여 의견의 대립이 있는바, 그 중 제1설은 “피고는 원고에게 ○○지방법원 2018타채1234 채권압류 및 추심명령에 따른 추심금 1,000만 원을 공탁의 방법으로 지급하고, 그 사유를 신고하라.”는 형식으로 함이 상당하고, 이 공탁판결에 기초하여 강제집행을 하여 집행기관이 배당등을 받아 그것을 공탁하여야 한다는 견해이고, 다른 제2설은 “피고는 ○○지방법원 2018타채1234 채권압류 및 추심명령에 따른 추심금 1,000만 원을 위 법원에 공탁하고 그 사유를 신고하라.”는 형식이 되고, 이는 간접강제(민집 제261조)의 방식으로 집행할 수 있다(민집 제248조 제4항)는 견해이다. 생각건대 이 경우 공탁청구의 소는 다른 모든 채권자들을 위한 대표소송의 성격을 가지고 있고, 배당재단의 형성에 그 주된 목적이 있으므로 제2설에 따른 주문 및 집행방식이 보다 바람직하다고 보이지만 그

261) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 379.

집행이 용이하지는 않다.

6. 추심채권자가 추심을 마쳤음에도 지체 없이 공탁 및 사유신고를 하지 아니한 경우에는 그로·인한 손해배상으로서, 제3채무자로부터 추심금을 지급받은 후 공탁 및 사유신고에 필요한 상당한 기간을 경과한 때부터 실제 추심금을 공탁할 때까지의 기간 동안 금전채무의 이행을 지체한 경우에 관한 법정지연손해금 상당의 금원도 공탁하여야 할 의무가 있다.²⁶²⁾

262) 대법원 2005. 7. 28. 선고 2004다8753 판결

제7절 현행법상 공탁제도 등의 문제점

I. 집행이 경합된 경우 제3채무자 공탁의 문제점

현행 민사집행법 제248조 제2항은 “금전채권에 관하여 배당요구서를 송달받은 제3채무자는 배당에 참가한 채권자의 청구가 있으면 압류된 부분에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다.”라고 규정하고, 제3항은 “금전채권중 압류되지 아니한 부분을 초과하여 거듭 압류명령 또는 가압류명령이 내려진 경우에 그 명령을 송달받은 제3채무자는 압류 또는 가압류채권자의 청구가 있으면 그 채권의 전액에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다.”라고 규정하고 있으며, 이를 민사집행법 제248조 제1항의 권리공탁 규정과 대비하여 의무공탁 규정이라고 부르고 있다.

그런데, 위 규정은 다음과 같은 몇 가지 문제점을 안고 있다. 아래에서 차례로 살펴보기로 한다.

1. 입법체제상의 불일치

가. 구 민사소송법 제581조 제1항, 제2항은 원래 일본의 구 민사소송법 제621조 제1항, 제2항²⁶³⁾을 그대로 번역·승계한 것인데, 위 일본의 규정은 독일 민사소송법 제853조를 본받아 만든 규정이다.

독일 민사소송법 제853조는, 「Mehrfache Pfändung einer Geldforderung(금전채권의 압류 경합)」이란 제목하에, “Ist eine Geldforderung für mehrere Gläubiger gepfändet, so ist der Drittschuldner berechtigt und auf Verlangen eines Gläubigers, dem die Forderung überwiesen wurde, verpflichtet, unter Anzeige der Sachlage und unter Aushändigung der ihm zugestellten Beschlüsse an das Amtsgericht, dessen Beschluss ihm zuerst zugestellt ist, den Schuldbetrag zu hinterlegen(금전채권이 다수의 채권자를 위하여 압류된 때에는 제3채무자는 최초로 송달받은 압류명령을 한 구법원에 그 사유를 신고함과 함께

263) 일본 구 민소법 제621조 「金銭債權の第三債務者の債務額供託」 ① 金銭ノ債權ニ付キ配當要求ノ送達ヲ受ケタル第三債務者ハ債務額ヲ供託スル權利アリ ② 第三債務者ハ配當ニ與カル或ル債權者ノ求ニ因リ債務額ヲ供託スル義務アリ ③ 第三債務者債務額ヲ供託シタルトキハ其事情ヲ裁判所ニ届出シ可シ」이라고 규정하고 있었다.

송달받은 모든 압류명령을 제출하고 채무금을 공탁할 수 있고, 그 채권을 이부받은 채권자의 요구가 있는 경우에는 그 공탁의무를 부담한다.”라고 규정하고 있다.

나. 그런데 일본은 위 독일법 규정을 승계할 때 독일법이 일본법의 체계와 달리 압류우선주의를 취하고 있는 것을 간과하고 말았다(적어도 위 규정이 자신들의 입법 체제인 채권자평등주의와 맞지 않다는 것을 간과하였다고 보여진다).

다. 위 독일법 제853조는 압류가 경합하는 경우 제3채무자가 그 채무액을 공탁할 권리가 있고, 또 그 중 이부받은 채권자의 요구가 있으면(즉, 공탁청구가 있으면) 이를 공탁할 의무가 있다는 것인데, 압류우선주의를 취하는 경우에는 위 규정이 말썽을 일으키지 아니한다.

압류 경합의 경우 압류명령을 송달받은 제3채무자로서는 자신의 판단하에 우선권이 있는 채권자의 추심청구에 응하여 이를 지급해도 되고, 그 판단이 어렵다고 생각하면 위 조항의 전문에 따라 공탁을 하면 된다(우선권의 판단을 잘못 그르치면 이 중변제의 위험을 질 수 있으므로 제3채무자로서는 안전하게 공탁하는 방법을 더 선호할 수도 있다). 독일의 경우에도 위 조항의 후문과 같이 이부채권자의 요구에 따라 의무공탁을 하는 사례는 별로 많지 않을 것이고, 대체로 전문에 따라 이를 처리할 것이지만 배당절차에서 기회를 엿보고자 하는 압류상 후순위인 채권자의 공탁청구가 있을 수도 있으므로 후문의 존재의의가 전혀 없는 것은 아니다. 따라서 독일법상의 위 제3채무자 공탁 조항은 압류우선주의하에서 문제를 일으킬 여지가 없는 타당한 규정에 해당한다.

라. 그러나 위 규정 체제를 채권자평등주의를 취하는 일본법과 우리법에 그대로 들여오면, 문제가 생기기 시작한다. 즉 압류채권자들 사이에 우선권이 없기 때문에 어느 채권자든 제3채무자에게 추심청구를 할 수 있고 또한 제3채무자는 어느 채권자에게든 채무액을 지급해도 된다. 제3채무자가 누가 우선권이 있는지 여부를 판단할 필요가 없으며 누구에게 지급하든 면책된다.

그런데 아래에서 자세히 살펴보겠지만, 제3채무자로부터 채무액을 추심한 채권자들은 자신에게 들어온 돈을 다른 채권자들과 나누어 갖고 싶은 생각이 별로 없거나 혹은 법률규정을 잘 알지 못하는 등의 이유로, 채권자평등주의를 위한 최소한의 안전장치로 마련한 민사집행법 제236조 제1항의 추심신고를 하지 않거나 압류 경합의 경우 민사집행법 제236조 제2항에 따른 공탁·사유신고를 하지 않아 결국 채권집행절차

전체가 파행으로 빠져들게 되는 것이다.

마. 또한 다음에 다시 보듯이, 압류명령을 받은 채권자로서는 이러한 상황을 이용하여 추심명령을 얻은 후 추심하는 것이 더 유리하므로 제3채무자에게 공탁청구를 할 필요성을 거의 느끼지 못하게 되어 '다른 채권자의 공탁청구'를 전제로 하고 있는 위 의무공탁 규정이 또한 거의 필요가 없는 규정이 되고 만다.

바. 일본은 일찍이 제3채무자의 공탁에 관한 위 규정이 자신의 입법태도와 맞지 않은 것을 인식하고 1980년경 민사집행법을 제정하면서 권리공탁과 의무공탁에 관한 내용을 전면적으로 개정해 버렸다.²⁶⁴⁾

2. 실제적인 문제점

우선, 위 규정에서 '배당에 참가한 채권자의 청구' 또는 '압류 또는 가압류채권자의 청구'라는 것은 위와 같은 압류채권자 등의 공탁청구를 말하는 것이고, 그 지급청구를 의미하는 것이 아니다(가압류채권자가 이에 포함되어 있는 것을 생각하면 그 의미를 바로 알 수 있으며, 원래 입법취지도 그러하다). 즉 압류채권자 또는 배당요구채권자 등이 제3채무자에게 피압류채권액을 공탁해달라는 청구를 하면 그때에 비로소 제3채무자는 그 채무액을 공탁할 의무가 있다는 것이 위 규정의 취지이다.

하지만, 위와 같은 규정태도는 채권집행의 실무를 잘 이해하지 못하고 만들어진 규정이라고 볼 수밖에 없다.

왜 그런가 하면, ① 먼저 채권집행에 있어서는 부동산집행과 달리 제3채무자가 공탁을 하여 그 절차의 주도권이 집행법원으로 넘어오기 전까지는 어떤 채권자가 당해 피압류채권에 대하여 압류 또는 가압류집행을 하였는지 등에 관한 집행의 상황이 전혀 다른 채권자에게 통지 또는 고지가 행해지지 않기 때문에 거의 모든 채권자들은 배당요구를 하기보다는 압류 또는 가압류의 집행방법을 이용하여 절차에 참가하게 되

264) 우리와 같은 공탁규정을 두고 있던 일본은 일찍이 이러한 문제점을 주목하고 채권자평등주의 진정한 실현을 위하여 민사집행법을 민사소송법으로부터 분리하면서 제3채무자의 의무공탁규정을 획기적으로 변화시켰다. 즉 일본 민사집행법 제156조는 「① 제3채무자는, 압류에 관계된 금전채권의 전액에 상당하는 금전을 채무이행지의 공탁소에 공탁할 수 있다. ② 제3채무자는 다음 조항(추심소송규정) 제1항에 규정하는 소의 소장을 송달받을 때까지, 압류에 관계된 금전채권 중에 압류되지 아니한 부분을 초과하여 발하여진 압류명령 또는 가압류명령의 송달을 받은 때에는 그 채권 전액에 상당하는 금전을, 배당요구의 뜻을 기재한 문서의 송달을 받은 때에는 압류된 부분에 상당한 금전을 채무이행지 공탁소에 공탁하여야 한다. ③ 제3채무자는, 전 제2항의 규정에 의한 공탁을 한 때에는 그 사정을 집행재판소에 신고하여야 한다.」라고 규정하고 있다[浦野雄幸, 逐條概説 民事執行法, 社團法人商事法務研究會(1980), 230. 참조].

며, 실무상으로도 배당요구를 하는 채권자는 거의 있지 아니하다. 이런 상황에서 그러한 배당요구채권자의 공탁청구는 거의 일어날 수 없는 일이라고 보아야 한다. ② 또한 가압류채권자의 경우에는 채권의 처분금지에만 관심이 있고 아직 자신이 가압류 상태이므로 오히려 제소명령 등이 있으면 본안소송에 집중하는 경향이 있을 뿐 아직 그 상황에서 제3채무자에게 공탁청구를 할 적극적 의미를 느끼지 못하는 것이 대부분이다. ③ 그리고 압류채권자의 경우에는 우리 민사집행법이 추심명령을 받은 채권자에 대한 지급을 허용하고 있으므로, 대부분 추심명령을 얻어서 추심하는 것이 더 유리한 것을 알고 있다(아래에서 다시 살펴보겠지만, 이 경우 추심공탁에 관한 민사집행법 제236조 제2항이 불완전하게 규정되어 있었던 탓으로 추심채권자에게 거의 전 부명령과 같은 독점적 효과를 부여하고 있었고 당시에는 이러한 미흡한 법률 규정을 이용하는 채권자들도 있었다). 이런 상황에서 미온적인 대책에 불과한 공탁청구를 하는 채권자들은 거의 없다고 봐도 과언이 아니다.

이러한 이론적·실제적 이유 등으로 인해 압류채권자 등이 공탁청구를 한 때에 제3채무자에게 공탁을 할 의무를 부과하는 위 규정은 그 동안 거의 사문화되어 있는 상태였다. 저자로서도 약 3년 가까이 채권집행실무를 한 바 있으나, 위 규정에 따라 제3채무자가 공탁을 한 사례를 한 건도 본 적이 없었다.

3. 민사집행법 제236조 제2항의 오작동(誤作動)에 따른 문제점

가. 민사집행법 제248조 제2항, 제3항이 단지 실제상 사문화되어 있다는 정도의 문제점만을 안고 있다면, 그것은 어느 정도 수인 가능한 하자에 불과할 것이다. 그러나 이하에서 보드시피 위 규정들은 상당히 심각한 문제점을 가지고 있으며 그것이 지금까지의 채권집행 자체의 파행적 운영에 기여한 바가 크다고 볼 수 있다.

나. 현행 민사집행법 제236조 제2항은, “제1항의 신고(추심신고를 말함) 전에 다른 압류·가압류 또는 배당요구가 있었을 때에는 채권자는 추심한 금액을 바로 공탁하고 그 사유를 신고하여야 한다.”라고 규정하고 있는데, 의무공탁을 규정하는 민사집행법 제248조 제2항, 제3항의 태도는, 민사집행법 제236조 제2항의 규정 방식과 굉장히 밀접한 관련이 있다.

다. 우리 민사집행법이 인정하는 압류명령을 기초로 추심명령을 받은 채권자의 행위 형태를 양 규정에 따라 추적해보면 다음과 같이 볼 수 있다. 즉 「㉠ 채권자는 압류명령을 발령받은 후(또는 압류명령과 동시에) 집행법원으로부터 추심명령을 발령

받는다. ㉠ 추심명령을 발령받은 채권자는 당해 피압류채권에 대하여 집행의 경합이 있다고 하더라도 제3채무자에게 추심금의 지급을 구할 수 있다. ㉡ 제3채무자는 추심채권자의 추심청구가 있는 경우 그 채권자에게 채무액을 지급할 수 있다. ㉢ 제3채무자로부터 채권액을 추심한 채권자는 민사집행법 제236조 제1항에 따라 추심채권액을 법원에 신고해야 한다. ㉣ 다만, 추심신고 전에 다른 압류·가압류 또는 배당요구가 있었을 때에는 채권자는 추심한 금액을 바로 공탁하고 그 사유를 신고하여야 한다.」가 바로 그것이다. 위 과정을 세심히 살펴보면, 우리 민사집행법은 집행이 경합하는 경우라도 제3채무자로 하여금 추심채권자에게 채무액을 지급하는 것을 허용하고 있는데, 바로 그것을 인정하고 전제 또는 안전장치는 다른 아니라, 집행이 경합하고 있는 경우 추심채권자로 하여금 추심채권액을 공탁하고 사유신고하여야 한다고 규정하고 있는 민사집행법 제236조 제2항의 존재가 그것임을 알 수가 있다. 이는 집행이 경합하는 경우에도 채권자의 공탁청구가 없으면 바로 추심채권자에게 지급할 수 있음을 내포하고 있는 민사집행법 제248조 제2항, 제3항이 채권자평등주의를 이념으로 하는 우리 민사집행법의 체제와 잘 어울리려면 민사집행법 제236조 제항이 오류 없이 작동해야 한다는 것을 의미하는 것이다.

라. 그런데, 문제는 위 민사집행법 제236조 제2항이 제대로 작동하지 않는다는 데에 있다. 실제로 있어서 위 규정이 어떻게 오작동하는지 한번 예를 들어서 보기로 한다.

[사례] 甲이 1,000만 원의 채권을 가지고 채무자 A가 제3채무자 B로부터 지급받을 1,000만 원의 채권(피압류채권)에 대하여 압류 및 추심명령을 얻었다. 그 후 A의 다른 채권자 乙은 1,000만 원의 채권을 가지고 위 피압류채권에 대하여 다시 압류 및 추심명령을 받았고, 또 다른 채권자 丙은 400만 원의 채권을 가지고, 다른 채권자 丁은 200만 원의 채권을 가지고 각 위 피압류채권에 대하여 압류 및 추심명령을 얻었다.

마. 위 사례라면, 피압류채권 1,000만 원이 채권자들인 甲, 乙, 丙, 丁의 채권액 합계인 2,600만 원에 이르지 못하므로 민사집행법 제235조에 따라 압류의 경합이 발생하게 되며, 이에 따라 위 채권자들의 각 압류의 효력은 피압류채권 전체에 대하여 미치게 된다.

바. 그런데 이와 같은 경우에 만일 제3채무자인 B가 피압류채권에 관하여 많은 채권자들로부터 압류 및 추심명령이 송달되어 오므로, 이를 민사집행법 제248조 제1

항에 따라 집행법원에 공탁하고 사유신고를 해버렸다면, 집행법원이 위 공탁 및 사유 신고에 따라 배당절차를 진행하여 위 채권자들에게 배당을 해주면 될 것이므로 별 문제가 없다.

그러나 제3채무자인 B가 채권자들로부터 각 압류 및 추심명령을 송달받은 후 채권자들 중 1인인 乙이 1,000만 원에 대하여 추심청구를 하므로, 그에게 피압류채권 전액을 모두 지급해버린 경우 등에는 문제가 발생하기 시작하게 된다. 즉 채권자 乙은 이 경우에 채권을 추심하였으면 민사집행법 제236조 제1항에 따라 추심한 채권액을 법원에 신고하여야 하는데도 실무상 이와 같은 추심신고를 하는 채권자가 거의 없다는 것이다. 다른 채권자들과의 “살벌한” 경쟁 속에서 일단 돈을 선점한 채권자 乙은 자신의 수중에 위 1,000만 원이 들어온 사실을 기뻐하고 또 그와 같은 은총을 베풀어주신 하느님께 감사하면서 위 규정에 따른 추심신고를 해야 하는 사실을 아예 모르거나 또는 알게 되었다고 하더라도 그 돈을 다른 채권자들과 나누어 가질 생각이 전혀 없으므로 그저 이를 들고 집으로 향할 뿐 그 이후는 아무런 소식이 없게 되고 만다. 그리고 실질상 다른 채권자들인 甲, 丙, 丁은 자신들의 “파이(pie)”가 어떻게 사라지게 된 지도 잘 모른 채 이에 대하여 사실상 권리를 잃게 되고 만다.

다시 말해 위 민사집행법 제236조 제2항은 그야말로 “양심우산” 또는 “양심자전거”와 같은 규정이라고 볼 수 있으며,²⁶⁵⁾ 아무런 대책도 없이 끊임없이 국민들의 양심을 시험하는 방임적 규정인 것이다.

사. 물론 이 경우 甲, 丙, 丁 등 채권자들로서는 이후 乙이 제3채무자로부터 채권 전부를 추심하였으나 그에 불구하고 민사집행법 제236조에 따른 추심신고를 하지 않은 사실을 알게 된 경우 乙에게 취할 수 있는 조치가 있기는 하다. 즉 이미 본 바와 같이 甲 등은 乙을 상대로 추심한 금원을 법원에 공탁하고 그 사유를 신고할 것을 구하는 소를 제기할 수 있는데, 이를 인용하는 때의 주문 방식에 관하여는, 「피고는 원고에게 ○○지방법원 2018타채○○○○호 채권압류 및 추심명령에 따른 추심금 1,000만 원을 공탁의 방법으로 지급하고 그 사유를 신고하라.」는 형식으로 함이 상당하고 이 공탁판결에 기초하여 강제집행을 하여 집행기관으로부터 배당등을 받아 그것을 공탁하여야 한다는 견해(제1설)와 「피고는 ○○지방법원 2018타채○○○○호 채권압류 및 추심명령에 따른 추심금 1,000만 원을 위 법원에 공탁하고 그 사유를 신

265) 채권금액이 클 경우 이러한 “양심우산” 또는 “양심자전거”가 제자리에 돌아오지 않을 것은 거의 자명하다고 볼 수 있다.

고하라.」는 형식이 되고 이는 간접강제(민집 제261조)의 방식으로 집행할 수 있다는 견해(제2설)가 있다.²⁶⁶⁾

그러나 이와 같이 복잡한 방법을 평범한 다른 채권자 甲 등이 알기도 어렵거나 와 설사 안다고 하더라도 위 제1설, 제2설 모두 이론상으로는 그럴 듯하나 실제상을 그대로 실행하기에는 참으로 지난(至難)한 것이고 또 일반적으로 ‘돈을 권 자는 더 멀리 가기 때문에(Wer das Geld fängt, der läuft ferner)’ 다른 채권자가 위와 같은 소송에서 승소한다고 하더라도 만일 이미 돈을 손에 권 추심채권자가 소재불명이라도 된다면 위 판결에 따른 집행 자체가 어렵게 되고 앞서 본 집행방법 등에 관한 논의 역시 탁상공론(卓上空論)이 되어버리기 때문에 대부분의 채권자들은 이를 포기하고 만다. 또한 이 경우 어떤 한 채권자가 소송을 제기하여 승소한다고 하더라도 자신이 그 금액을 모두 갖는 것도 아니고 단지 배당재단이 되어 다른 채권자들과 안분하여 배당받아가야 하는데, 이러한 상황에서 자신이 특히 나서서 시간, 노력, 비용을 들여 소송을 제기할 메리트를 찾기 어려운 경우가 많을 것이다.²⁶⁷⁾

결국은 ‘먼저 손을 쓴’ 채권자 을이 부당하게 위 1,000만 원에 대하여 우선적 지위를 부여받게 되는 결과에 이르고 마는 것이다(이것은 우선주의를 취하는 독일법에서의 의미와도 다른 것이며, 평등한 위치에 있으면서도 단지 돈을 먼저 받아갔을 뿐임을 의미하는 것으로서 굳이 이를 이름붙이자면 ‘약탈적 우선주의’라고 부를 수 있겠다).

아. 이러한 약탈적 우선주의는, 예컨대 위 사례에서 만일 제3채무자인 B가 채권

266) 손진홍, 채권집행의 이론과 실무(상), 476.

267) 이전과 달리, 최근에는 채권자들의 권리의식이 강해져서 특히 회사 등의 경우에는 추심금을 공탁하지 않는 추심채권자를 상대로 추심금 공탁청구의 소를 제기하는 사건 수가 늘어났고, 이러한 추세에 발맞추어 대법원 또한 대법원 2005. 7. 28. 선고 2004다8753 판결에서, “추심채권자는 피압류채권의 행사에 제약을 받게 되는 채무자를 위하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 채권을 행사하고, 나아가 제3채무자로부터 추심금을 지급받으면 지체 없이 공탁 및 사유신고를 함으로써 압류 또는 배당에 참가한 모든 채권자들이 배당절차에 의한 채권의 만족을 얻도록 하여야 할 의무를 부담한다 할 것인바, 이는 구 민사소송법(2002. 1. 26. 법률 제6626호로 전문 개정되기 전의 것) 제569조 제2항이 채권을 추심한 추심채권자가 그 사유를 법원에 신고하기 전에 다른 압류, 가압류 또는 배당요구가 있는 때에는 추심한 금액을 ‘지체 없이’ 공탁하고 그 사유를 신고하여야 한다고 규정하고 있는 점에 비추어 당연하다고 할 것이므로, 만일 추심채권자가 추심을 마쳤음에도 지체 없이 공탁 및 사유신고를 하지 아니한 경우에는 그로 인한 손해배상으로서, 제3채무자로부터 추심금을 지급받은 후 공탁 및 사유신고에 필요한 상당한 기간을 경과한 때부터 실제 추심금을 공탁할 때까지의 기간 동안 금전채무의 이행을 지체한 경우에 관한 법정지연손해금 상당의 금원도 공탁하여야 할 의무가 있다.”라고 판시하여 다른 채권자들의 이익을 보다 도모하고, 나아가 추심채권자의 공탁의무를 간접적으로 강제하기 위한 판결을 내고 있다.

자들의 추심청구에 대해 丙에게는 400만 원을, 丁에게는 200만 원을 지급하고 나머지 400만 원은 공탁해버렸다가, 혹은 甲에게는 400만 원을, 丙에게는 400만 원을, 丁에게는 나머지 200만 원을 각 지급하고, 乙이 다시 추심청구하자 더 줄 것이 없다고 거절해버렸다가 하는 경우와 같이 많은 채권자들에게 그들이 추심청구하는 대로 또는 제3채무자인 자신이 주고 싶은 대로의 금액만큼 모두 지급해버린 경우에 이르게 되면, 채권의 운명은 혹은 누가 먼저 제3채무자에게 가서 손을 내밀었는지에 따라, 혹은 제3채무자가 누구에게 지급했는지에 따라 달라지게 되버린다(극단적으로 말하면, 제3채무자로서는 채권자들의 추심청구에 대하여 지급해도 되고, 지급하지 않아도 별 문제가 없으므로, 자신과 이해관계가 있는 어느 한 채권자와 공모하여 그에게만 모두 지급하고 다른 채권자들의 지급청구를 거절해버리거나 채무자와 공모하여 집행증서 등으로 허위의 채권자를 만들어 채무액을 빼돌릴 수도 있으므로, 강제집행 면탈이 이루어지게 되며, 채권집행의 공정성 여하가 어떻게 보면 단지 사인인 제3채무자의 손에 달려 있게 되어 더욱 혼란을 가중할 우려도 있게 되는 것이다). 그리고 그것을 나중에 바로잡기 위해 소송을 해야 한다고 한다면 그 절차적 비용은 감당하기 어려울 정도에 달할 수도 있다.

자. 이와 같이 추심채권자가 추심을 한 이후에 민사집행법 제236조 제1항, 제2항에 따라 추심신고 또는 공탁을 하지 않으면 채권집행절차상으로도 치명적인 결함을 낳게 된다. 즉 현행 민사집행법 제247조 제1항 제2호는 “채권자가 제236조에 따른 추심의 신고를 한 때”를 배당요구의 종기로 정하고 있는데, 추심채권자가 추심신고를 하지 않음에 따라 배당요구의 종기가 도래하지 않게 되고 그에 따라 당해 배당절차에 참가할 수 있는 채권자를 확정할 수가 없게 된다. 또한 집행이 경합하고 있는 상태라면 추심채권자가 민사집행법 제236조 제2항에 의해 추심한 금원을 집행법원에 공탁하고 사유신고를 한 후 집행법원에 의한 배당절차가 종료해야만 그 사건이 종료하게 되는데, 이러한 공탁 및 사유신고가 없는 결과 위 집행사건은 종료되지 않고 영구미제로 남게 되는 것이다.

4. 개정 의견

가. 다시 말하지만, 현행 민사집행법 제248조 제2항, 제3항은 그 규정의 배경에 민사집행법 제236조 제2항의 정상적으로 작동되는 상황을 전제로 하여 규정되어 있는 것이다. 그런데, 위에서 살펴본 바와 같이 민사집행법 제236조 제2항은 “양심우

산” 또는 “양심자전거”와 같은 규정으로서 이미 실제에 있어서 정상적으로 작동되기 어려운 난점을 그 속에 품고 있다. 이와 같이 민사집행법 제236조 제2항이 제대로 작동되지 않는 상황에서 그로부터 발생하는 문제점을 치유하기 위해서는 결국 민사집행법 제248조 제2항, 제3항의 의무공탁규정을 개정하는 수밖에 없게 되는 것이다. 즉 이를 채권자가 경합하더라도 ‘채권자의 공탁청구’가 있을 때에 비로소 제3채무자로 하여금 공탁의무를 부여하는 취지의 불완전한 의무공탁규정에서, 채권자가 경합하는 경우라면 채권자의 공탁청구 여하에 불구하고 제3채무자로 하여금 ‘공탁해야만’ 채무를 면할 수 있도록 개정해야 하는 것이다.

이렇게 개정하게 되면, 채권자가 경합하는 경우에는 채권자의 공탁청구와 관계없이 그 중 1인의 채권자가 추심청구(추심소송)를 하더라도 그에 응해서는 안 되고 위조항에 따라 공탁하여야만 채무를 면할 수 있게 된다 따라서 채권자가 경합하고 있는 데도 불구하고 그 중 1인의 채권자의 추심청구에 응하여 채무액을 지급했다가는 이중지급의 위험을 부담해야 하는 것이다.

그럼에 따라, 채권자가 경합하는 경우에는 그 누구도 우선적으로 추심을 하지 못하게 되고, 나중에 추심소송의 결과에 따라 자신의 몫만 배당받아가게 되므로 우리의 경우에서 나타나는 ① 배당요구 중기 불확정의 문제 ② 동등한 일반채권자인데도 실질적으로 먼저 추심하는 자가 결과적으로 이익을 보게 되어버리는 문제 등이 나타나지 않게 되는 것이다.

나. 이러한 개정안에 대하여 다음과 같은 세 가지 정도의 문제 제기가 있을 수 있다. 즉 ① 추심명령까지 얻은 채권자의 추심권을 입법적으로 제한하는 것은 잘못이라는 견해 및 ② 제3채무자로 하여금 채권자가 경합되었는지 여부를 확인하도록 하는 것은 문제가 있다는 견해와 ③ 제3채무자가 경합 채권자 중 일방 채권자에게 모두 지급함으로써 생기는 채권자들 사이의 불균형은 지급받지 못한 채권자들로 하여금 지급받은 채권자를 상대로 부당이득반환청구등을 하도록 하면 된다는 견해 등이 그것이다.

그러나 위 모든 견해들은 다음과 같은 이유로 타당하지 못하다. 우선 ①에 관하여는 우리 민사집행법은 채권자평등주의(압류의 효력, 경합의 경우 압류효 확장, 배당요구의 효력 등)를 취하고 있다. 이와 같이 채권자평등주의를 취하는 우리 집행법상 채권자가 추심명령을 받더라도 다른 채권자의 경합이 없을 때에만 만족을 얻을 수 있는 것일 뿐, 다른 채권자가 경합하는 데에도 그에 불구하고 독점적 만족을 얻을 권

리까지 부여되어 있는 것은 아니다. 이는 입법에 의해 채권자의 추심권을 제한하지는 것이 아니다. 집행이 경합하는 경우 다른 채권자가 존재하므로 당해 피압류채권액에서 당해 채권자가 「가져갈 수 있는 돈」만 다른 채권자와 평등하게 배분받아가라는 취지인 것이다. 채권압류에 있어서 채권자의 추심권이란 동일한 채권에 대하여 다른 채권자의 존재가 발견되면 그 자체로 성질상 제한 받을 수밖에 없는 것이고, 만약 제3채무자에게 위와 같은 완전한 의무공탁을 인정한다고 하더라도 그것은 이러한 추심권의 본질적인 한계를 입법화시켜 놓은 것에 불과하므로 ①과 같은 비판은 적절하지 않다.

위 ②의 견해에 대하여는, 먼저 이론적으로 볼 때 채권집행에 있어서 제3채무자에게는 원래 집행절차에 협력할 의무가 지워져 있는데, 이러한 절차협력의무는 다른 아니라 자신이 원래 채무자에게 지고 있는 채무를 이행하지 않은 데에서 비롯되는 것이다.

이러한 견지에서 우리 집행법도 규정상 또는 해석상으로 압류의 경우 채무자에 대한 지급금지의무(민집 제227조 제1항), 채권자 경합의 경우 채권자의 청구에 따라 공탁할 의무(민집 제248조 제2항, 제3항), 채권자 등의 최고에 대하여 진술할 의무(민집 제237조), 진술을 해태한 경우 손해배상의무, 사유신고가 없거나 불비한 경우 행해지는 집행법원의 조회에 대한 회답의무 등을 인정하고 있는 것이다.

완전한 공탁의무를 인정한다고 하더라도, 제3채무자는 채권자 경합 혹은 압류의 경합 등의 용어를 정확히 알지 못하더라도 그저 자신에게 압류(또는 가압류) 결정문을 송달시킨 채권자가 1명인지 2명, 3명인지 또는 그 이상의 것인지를 손가락으로 헤아릴 수만 있거나 하면 충분하다고 볼 수 있다. 즉 채권자가 2명 이상이면 추심청구를 받더라도 지급을 하지 않고 공탁하면 그 채무를 면하게 되는 것이다. 우리 집행법 제248조 제1항은 권리공탁을 인정하고 있고, 더욱이 우리 대법원은 청구금액의 총액이 피압류채권을 넘지 않는 부진정 압류의 경우에도 제3채무자의 공탁에 의한 채무 면책을 인정하고 있으므로,²⁶⁸⁾ 제3채무자가 이러한 의무 때문에 실제상 불이익을 당하는 경우는 아래에서 보는 비용상 문제를 제외하고는 상정하기 어렵다(다만, 법률

268) 대법원 1996. 6. 14. 선고 96다5179 판결【판결요지】민사소송법 제581조 제1항의 입법 취지에 비추어 보면, 동일한 채권에 대하여 복수의 압류명령이 있더라도 각 압류의 법률적 성질상 압류액의 총액이 피압류채권액을 초과하지 아니하여 본래의 의미에서의 압류의 경합으로 볼 수 없는 경우에도, 제3채무자의 입장에서 보아 그 우선순위에 대하여 문제가 있는 등 압류의 경합이 있는지 여부에 대한 판단이 곤란하다고 보이는 객관적 사정이 있는 경우에는, 그 규정을 유추적용하여 제3채무자에게 공탁에 의한 면책을 인정하는 것이 상당하다.

개정 후에 실무의 혼동을 막기 위해 예규를 제정하여 압류명령의 결정문 아래에, “채권자가 경합하는 경우에는 채권자 중 1인의 추심청구에 응하여서는 아니되며, 민사집행법 제248조 제2항 또는 제3항에 따라 공탁을 하여야만 채무를 면할 수 있습니다.”는 취지의 문구를 기재하여 제3채무자에게 그 결정문을 송달하도록 하는 것이 보다 바람직할 것이다).

그와 같이 공탁할 의무를 부담함으로써 제3채무자가 이전의 의무보다 더 부담하게 것은 결국은 공탁비용 문제일 것인데, 이에 대해서는 민사소송비용법 제10조의2 제1항이 이미 그에 대한 전보(填補)를 예정해 두고 있으므로 별다른 문제가 없다(다만, 위 규정도 개정이 필요한 점이 있고, 이에 대해서는 나중에 다시 설명하기로 한다). 즉 제3채무자가 공탁의 의무를 이행함으로써 발생하는 경제적 불이익은 의무공탁의 경우에 공탁비용을 제3채무자에게 최우선적으로 환급해줌으로써 거의 완전히 전보(填補)될 수 있는 것이다.

이익형량의 견지에서 보더라도, 이미 채무자에 대하여 채무를 지급하지 않아 채권자와 채무자 사이의 법률관계의 테두리 속으로 들어선 제3자로 하여금 채권자가 경합된 상태에서 임의의 지급을 금지하고 공탁하도록 함으로써 생기는 제3자의 불이익은 채권자 경합의 경우 임의의 지급을 금지하고 공탁하게 함으로써 생기는 집행절차상의 이익과 다른 채권자들 또는 채무자의 이익과 비교할 때 도저히 견줄 바가 못 된다.

또한 ③의 주장은, 그 자체가 본말이 전도된 것이다. 우리의 집행법은 그 구조가 기본적으로 채권자평등주의를 취하고 있어서 채권자 경합의 경우 어느 채권자에게도 우선권을 부여하고 있지 않다. 그런데도 그 취지에 반한 규정을 방치하여 그 중 일방 채권자가 “약탈적”으로 채권액을 모두 가져가도록 해놓고 그 후에 불의타를 입은 다른 채권자들로 하여금 지급받아간 채권자에 대하여 부당이득반환청구를 하거나 그 소송을 제기하도록 하는 것은 앞뒤를 분간하지 못하는 것이다.

좀 더 나이브(nive)하게 말한다면 그 주장을 하는 사람이 소송을 해야 하는 채권자들의 소송비용, 혹은 그 낭비한 시간과 노력 등을 모두 보상해줄 것인가 하고 묻고 싶다. 왜 불의타를 입은 다른 채권자는 아무런 잘못도 없이 ‘당연히 받아야 할’ 자기의 채권을 받지 못하고 또 그것을 받기 위해 채무자도 아닌 ‘다른 채권자’를 상대로 청구 또는 소송을 제기해야 하는가. 또 만약 제3채무자로부터 먼저 돈을 받아간 채권자가 소재불명이라도 되면 다른 채권자들은 ‘도대체’ 어떻게 해야 하는가. 아마도 대

부분의 채권자들은 그 채권을 포기해야 되는 상황에 이르게 될 것이다.

이는 입법적으로 잘못된 것의 뒤처리를 원인으로 잘 모르는 일반 채권자들에게 떠넘기고 있는 것과 다르지 않다고 보아야 하며, 이는 어찌보면 사법권의 방임이다.

다. 따라서 현재 우리의 제3채무자 의무공탁 규정(민집 제248조 제2항, 제3항)은 채권자가 경합하는 경우라면 그 중 1인의 추심권자에게 지급해버릴 수 있는 여지를 없애고 공탁에 의해 채무를 면하도록 해야 하며, 그와 같이 공탁된 채무액이 배당절차에서 다른 채권자들과 평등하게 배분될 수 있도록 개정되어야 한다. 그것만이 우리의 채권집행에 있어서 약탈적 우선주의가 횡행하는 것을 막을 수 있는 유일한 방법이라고 하겠다.

우리는 2002년 민사집행법 제정 및 시행에 있어서 이러한 문제점을 제거할 기회를 놓치고 만 것이며, 이제 다음의 개정시까지지는 채권자가 경합하는 경우에 있어서, ① 그 중 1인의 채권자가 추심청구를 한 경우라도 이에 응하지 않고 채무액을 민사집행법 제248조 제1항에 따라 권리공탁 해주는 제3채무자의 「현명함」과 ② 채무액을 추심하고서도 멀리 가지 않는 추심채권자의 「믿기지 않는 양심」에 의존할 수밖에 없게 되었다.

II. 제3채무자 공탁사유신고 규정의 문제점

1. 민사집행법 제248조 제4항은 “제3채무자가 채무액을 공탁한 때에는 그 사유를 법원에 신고하여야 한다. 다만 상당한 기간 이내에 신고가 없는 때에는 압류채권자, 가압류채권자, 배당에 참가한 채권자, 채무자, 그 밖의 이해관계인이 그 사유를 법원에 신고할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

이 규정은 제3채무자가 공탁을 하였더라도 사유신고를 하지 아니하는 한 배당요구의 종기가 도래하지 아니하여 배당절차가 사실상 진행되지 못하는 등 절차의 신속한 진행에 지장이 있으므로 채권자 등 다른 이해관계인에게도 사유신고권을 인정한 것이다.²⁶⁹⁾

2. 그리고 이미 본 바와 같이 제3채무자의 공탁에 관하여 민사집행법 제252조 제2호는 제3채무자가 공탁한 때에 배당절차가 개시되는 것으로 규정하고 있으나, 집

269) 앞의 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355.

행법원으로서 제3채무자가 그 사실을 신고하지 않는 한 공탁 여부를 알 길이 없으므로 실제상 제3채무자가 집행법원에 사유신고를 하였을 때에 배당절차가 개시되는 것이며, 또한 제3채무자가 그 공탁에 따른 사유신고를 했을 때에 배당가입의 차단효과가 발생하여 비로소 배당요구의 종기에 이르게 된다(민집 제247조 제1항 제1호).

3. 그런데 위 제248조 제4항의 규정이 위와 같이 절차의 신속한 진행과 채권자들의 보호를 위해 마련된 취지와 달리, 오히려 사유신고를 할 의무를 가지고 있는 자가 누구인지 애매하게 됨으로써 종종 배당요구의 종기를 확정하기 어려운 사정이 발생하기도 하는 것이다. 그 이유는, 위 규정의 본문은 제3채무자에게 사유신고의무를 부과하고 있는 듯 하지만, 다시 그 단서가 제3채무자가 위 제1항, 제2항에 따라 공탁하고서도 공탁사유신고를 하지 않을 경우 배당에 참가한 채권자 등이 이를 대신 할 수 있도록 함에 따라 제3채무자의 사유신고의무는 진정한 의무라기보다는 사실상 해도 되고 안 해도 무방한 의무가 되어버린 것이다. 또한 다른 채권자가 이에 관한 의무를 부담하고 있는 것도 아니다.

4. 그 때문에 제3채무자(특히 개인인 제3채무자)가 예컨대, 채권자가 경합하는 경우에 있어서 채권자의 관여 없이 민사집행법 제248조 제1항에 따라 권리공탁을 하고 다만 사유신고에 관해서는 자신의 어떤 사정으로 인해 혹은 자신이 이를 안해도 될 일이라고 생각하여 하지 않아 버린 경우를 생각해보면, 첫째로, 이때의 사유신고는 제3채무자의 의무가 아니기 때문에 제3채무자에 대하여 법원에서 그에 대해서만 사유신고를 위한 어떠한 조치를 취할 수가 없다. 둘째로, 제3채무자가 사유신고를 하고 배당절차로 나아가서 최고 또는 기일소환 등이 있어야만 다른 채권자로서는 제3채무자가 공탁을 한 것으로 인해 배당절차가 진행되는 것이라는 것을 비로소 알게 되는 것이고, 그 이전이라면 거의 모든 경우에 제3채무자가 채무액을 공탁하였음을 알 수 있는 방법이 없다. 그에 따라 위 규정의 단서에 따라 제3채무자가 공탁한 후 사유신고를 하지 않았음을 알고서 스스로 사유신고를 할 수 있는 방도를 찾기란 사실상 어렵다(설령 우연히 그러한 사정을 알게 되었다 하더라도 대부분 많은 시간이 흘러간 이후일 것이다). 셋째로, 압류채권자가 수십명이 되는 복잡한 사안의 경우를 보면 채권자들이 소재 불명인 경우가 많고, 또한 대부분의 채권자들은 제3채무자가 사유신고를 하지 않았음을 알게 되었다고 하더라도 자신의 여러 가지 사정(거리, 시간, 비용, 노력 등의 사정)을 들어 서로 다른 채권자가 사유신고를 해줄 것을 기대하고서 이를 태만히 취급할 경우가 많은데, 추심채권자의 공탁사유신고와 달리 이 경우에는 다른

채권자를 상대로 사유신고를 하라고 소송을 제기할 수 있는 것도 아니다.

이러한 사태가 발생하면, 배당가입의 차단효과 없으므로 또다른 채권자의 압류 또는 배당요구는 계속해서 늘어나고, 배당요구의 종기는 언제 확정될지 모르게 될 수도 있는 것이고, 위에서는 권리공탁을 하는 경우를 그 예로 들었으나, 의무공탁의 경우에도 그 사정은 별반 다르지 않다고 볼 수 있다.

5. 따라서 입법론적으로 볼 때에, 민사집행법 제248조 제4항의 단서는 삭제하는 것이 오히려 바람직하다고 본다.

제3채무자가 공탁하고 사유신고를 함으로써 지는 부담은 물론 여러 가지가 있겠지만 그 중 가장 큰 것은 비용의 부담이다. 그런데 제3채무자가 공탁의무의 이행으로서 공탁을 한 때에 그 비용과 공탁신고서 제출을 위한 비용을 집행법원에 신청하면 공탁금에서 지급을 받을 수 있고(민소비용법 제10조의2), 이러한 제3채무자가 청구하는 비용의 우선순위에 대하여는 명문의 규정이 없지만, 집행법원이 제3채무자의 청구에 따라 공탁금 중에서 지급하는 것이고 본질적으로는 배당등 절차 전에도 집행법원의 지급결정에 기초하여 지급할 수 있는 것이므로 엄밀하게는 배당금으로서 지급되는 것은 아니라고 하더라도 이를 배당표에 적는다고 한다면 절차비용보다도 우선하는 최선순위로 적어야 할 것이다.²⁷⁰⁾ 그렇다면 제3채무자에게만 온전히 사유신고의무를 지우더라도 자신의 채무를 면하면서 행위해야 할 정도를 넘어설 만한 크나큰 부담은 아니라고 할 것이다. 그리고 다른 채권자 등 이해관계인의 이익을 보호하기 위한다는 목적하에 마련한 단서 규정이 위와 같이 그 취지와 달리 오히려 그 이익에 반하는 결과를 가져올 가능성이 있다면 이는 개정되어야 한다고 본다.

6. 그러므로 보전대, 위 규정을 개정하는 방법에는 ① 위 단서 규정을 없애고 본문 규정, 즉 “제3채무자는 채무액을 공탁한 때에는 그 사유를 법원에 신고하여야 한다.”라고만 규정하는 방법과 그렇지 않고 ② 위 규정을 그대로 둔 채 만약 제3채무자가 공탁을 하고서도 사유신고를 하지 않으면 이를 다른 채권자들에게 최고 등으로 알리는 방법을 생각해 볼 수도 있으나, ②의 경우에는 채권자가 많을 때에 그 최고를 누구에게 해야 되는 것인지 등이 또한 불확실하기 때문에 선뜻 내키지 않는 방법이라 여겨지고, ①의 방법이 가장 간명하고 적절한 방법이라고 생각된다.

270) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 511.

III. 공탁법원과 사유신고법원이 다른 점에 관하여

1. 압류가 경합된 경우, 제3채무자는 공탁을 할 경우 채권자나 채무자의 보통재판적이 있는 집행법원에 공탁할 수 있다(민집 제19조 제1항). 그런데 그에 대한 사유신고는 그것이 진정한 압류 경합이 아닌 경우(압류명령의 집행채권의 총액이 피압류채권액을 넘지 않는 경우)이든 아니면 진정한 압류의 경합이 있는 경우이든 구별하지 않고 먼저 송달된 압류명령을 발령한 법원에 사유신고를 하여야 한다(민집규 제172조 제3항).

2. 위와 같이, 제3채무자의 채무액 공탁법원과 그 사유신고 법원이 다른 것이 실무상 다음과 같은 곤란한 사례를 발생시킬 수가 있다.

즉 예컨대 제3채무자가 공탁할 법원인 채권자 또는 채무자의 보통재판적 소재지가 甲 지방법원 관할이고, 그 사유신고를 해야 할 법원이 그 중 먼저 압류명령을 발령한 乙 지방법원인 경우를 생각해보자.

이 경우 제3채무자는 우선 甲 지방법원 관할 공탁소에 채무액을 공탁한 다음 다시 乙 지방법원까지 가서 사유신고를 해야 하는 불편이 따르게 된다. 그리고 나중에 배당절차가 진행되어 배당표가 확정된 경우 다른 대다수의 채권자들은 제3채무자가 사유신고를 하고 배당절차를 실시한 집행법원인 乙 지방법원에서 지급위탁서를 받아 이를 들고 甲 지방법원 관할 공탁소에서 공탁금을 찾아야 하는 더 많은 불편을 겪게 될 수 있는 것이다.

3. 따라서 현재 법령과 같이 일괄적으로 공탁법원과 사유신고법원을 이렇게 분리해놓는 방법을 조금 개선할 필요가 있다고 본다. 그 방법은 이후 다시 논의가 되어야 할 것이지만, 그 가운데 한 가지는 원칙적으로 위와 같이 운영을 하되, 다만 제3채무자로 하여금 위 사례와 같은 경우 현저한 손해 또는 지연을 피할 필요성이 있다고 판단될 때에는 공탁법원에 대하여 사유신고를 할 수 있다는 규정을 단서로 혹은 별도로 마련하는 것이 좋을 것이라고 생각된다.²⁷¹⁾

4. 그리고 이러한 사정은 공탁관의 사유신고에서도 비슷하게 나타난다. 현재 소

271) 현행법(민사집행규칙)이 구 민소법과 달리 사유신고를 할 법원을 먼저 압류명령을 발령한 법원으로 규정함에 따라 공탁법원과 사유신고법원이 달라져 위와 같은 문제점이 더 가중되었다고도 볼 여지가 있다.

액사건(청구금액 2,000만 원 이하)의 가압류는 군법원에서도 가압류를 발령할 수 있도록 하고 있는바, 예를 들어 채권자 甲이 채무자 乙에 대하여 1,000만 원의 청구채권으로써 A 군법원에 가압류신청을 하여 그 집행을 하자 채무자 乙이 위 청구금액 1,000만 원을 해방금 명목으로 위 군법원에 공탁하였는데, 이후 위 해방공탁금에 대하여 압류의 경합이 발생한 경우, A 군법원의 공탁관은 군법원에서 배당절차를 진행할 수 없으므로 甲 지방법원(현재 대법원 행정예규 제542호에 따른 공탁소 관할 집행법원 - 하지만 지금은 법에 명문의 규정이 있으므로 먼저 압류명령을 발령한 법원에 사유신고를 하도록 개정되어야 한다는 것에 대해서는 앞에서 서술한 바 있다)에 대하여 사유신고를 하게 될 것이다. 그러면, 이 경우도 채권자들은 배당절차를 실시한 집행법원인 甲 지방법원에서 지급위탁서를 받아 다시 A 군까지 가서 공탁금을 지급받아야 하는 불편함을 가지고 있는 것이다. 따라서 이 경우도 공탁관이 甲 지방법원에 사유신고를 한 때에는 그 공탁금도 甲 지방법원 관할 공탁소에 보낼 수 있는 별도의 규정을 마련함으로써 채권자들의 권리행사에 어려움이 없도록 하는 것이 바람직하다고 본다.

IV. 민사소송비용법 제10조의2 개정 필요성

1. 민사소송비용법 제10조의2 제1항은 “민사집행법 제248조의 규정에 따라 채무액을 공탁한 제3채무자는 압류의 효력이 미치는 부분에 해당하는 금액의 공탁을 위하여 지출한 비용 및 같은 조 제4항의 공탁신고서 제출을 위한 비용을 지급해 줄 것을 법원에 신청할 수 있다.”라고 규정하고 있는데, 이번 개정과 더불어 위 규정도 정비할 필요가 있다.

2. 민사집행법 제248조 제2항, 제3항이 불완전한 의무공탁을 규정하고 있을 때에는 그 규정에 따라서 즉 채권자가 경합하는 경우에 채권자가 공탁청구를 해서 공탁을 하는 사례는 거의 없었다. 이때에는 거의 모든 제3채무자가 채권자가 경합하는 경우에도 제248조 제1항의 권리공탁규정에 따라 공탁을 하고 사유신고를 하였다. 민집 제248조 제2항, 제3항이 채권자가 공탁청구를 해야만 그 규정에 따라 제3채무자가 의무공탁을 할 수 있다고 규정하고 있는 반면, 어떠한 채권자도 공탁청구를 거의 하지 않기 때문에, 3채무자가 위 제248조 제2항, 제3항에 의해 의무공탁을 하는 경우가 거의 없었고(이미 본 바와 같이 위 조문은 거의 이용되지 않는 상태였음), 제3채

무자는 채권자가 경합하는 경우에도 제248조 제1항에 따라 권리공탁을 하였던 것이다.

3. 그런데, 민사집행법 제248조 제1항이 규정하는 권리공탁은 제3채무자가 자신의 채무변제를 위하여 권리로서 하는 공탁으로서 이는 그 성질상 변제공탁과 똑같은 것이다.²⁷²⁾ 따라서 변제공탁을 하면서 제3채무자가 그 비용을 변상받지 않듯이 권리공탁의 경우에는 공탁비용을 제3채무자에게 지급할 필요가 없다. 제3채무자가 공탁비용지급청구권을 갖는 경우에는 권리로서 공탁하는 경우가 아니라 채권자가 경합하였기 때문에 의무로서 공탁하는 경우, 즉 의무공탁의 경우에만 이에 해당하는 것이다.

4. 현행 민사집행법하에서는 민사집행법 제248조 제2항, 제3항에 따른 의무공탁이 거의 행해지지 않고 채권자가 경합하는 경우에도 권리공탁으로써 처리했기 때문에 이를 굳이 구별하지 않은 채 두루몽실하게 제3채무자가 공탁하는 경우에는 권리공탁의 경우에도 모두 그 공탁비용을 변상해주는 식으로 실무가 그냥 처리하고 있으며(그렇지 않으면 비용변상해줄 일이 없다. 민사집행법하에서 의무공탁을 하는 사례는 거의 없고 모두 권리공탁을 하고 있기 때문이다), 그로 인한 낭비도 심하다. 그러나 이제는 이 실무를 고쳐야 하고 위 민사소송비용법이 만연히 “제248조”라고만 하고 있는 것도 “제248조 제2항, 제3항”으로 개정해야 한다.

5. 다시 말하지만, 권리공탁의 경우에는 제3채무자가 자신의 채무변제를 하는 위해(그 권리로서) 하는 공탁이므로 변제공탁과 같이 그 비용에 대한 변상을 요하지 않는다. 만일 권리공탁의 경우에도 제3채무자에게 그 비용을 변상해준다면 이는 부당하게 다른 채권자들이 받아야 할 돈을 제3채무자가 가져가는 것이 되고 마는 것이다.

6. 원래 의무공탁의 경우에 비용변상제도의 취지 자체는 채권자평등주의를 취하는 입법례하에서 채권자가 경합하는 경우 이후 집행절차의 적정화 또는 형평화를 위해 제3채무자에게 공탁을 해야만 채무를 면한다는 의무를 부과하면서 다만 그 공탁을 하면서 든 비용이 있다면 그 실손해를 전보(填補)해주고자 하는 취지에서 나온 것이다.

7. 따라서 이제 민사집행법 제248조 제2항, 제3항의 의무공탁규정을 완전하게

272) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 354. 참조

개정된 후 제3채무자가 의무로써 공탁을 해야만 채무를 면하게 되는 그러한 상황에 대해서만 제3채무자에게 공탁비용을 변상해주고, 권리공탁의 경우에는 채권액이 온전히 채무변제에 사용될 수 있도록 위 민사소송비용법의 규정도 개정하고 예규를 제정하여 그와 같이 운용되도록 하여야 할 것이다.

[8 - 1] 공탁사실통지서

○ ○ 지 방 법 원	
공 탁 사 실 통 지 서	
(가)압류채권자 ○ ○ ○ 귀하	
(가)압류채무자 ○ ○ ○ 귀하	
사 건	
채 권 자	
채 무 자	
제3채무자	
위 (가)압류사건의 피(가)압류채권이 아래와 같이 공탁되었음을 통지합니다.	
아	래
공탁사건번호	
금 액	
공 탁 자	
피 공 탁 자	
공 탁 일 자	
20 . . .	
○ ○ 지 방 법 원	
공 탁 공 무 원 (인)	

[8 - 2] 사유신고불수리증명신청

사유신고불수리증명신청서

신 청 인 김 갑 동
(제3채무자) 서울 서초구 서초대로 52길 ○ ○

신청인이 제출한 아래 공탁서 1통에 관하여, 민사집행법 제248조 제1항에 의한 사유신고서를 귀 법원이 수리하지 않았음을 증명해주시기 바랍니다.

아 래

공탁연월일	2018. 10. 15.
공탁번호	2018금제○○○○호
공탁금액	1,000만 원
공탁원인	민사집행법 제248조 제1항
공 탁 자	김 갑 동

20 . . .

신청인 김갑동(인)

○ ○ 지 방 법 원 귀 중

[8 - 3] 사유신고불수리결정

○ ○ 지 방 법 원
결 정

사유신고인 김갑동
(제3채무자) 서울 서초구 서초대로 52길 ○ ○

위 사유신고인(제3채무자)이 ○ ○ 공탁소에 대하여 한 별지공탁목록 기재의 공탁에
관련된 사유신고서 1통에 관하여 이 집행법원은 다음과 같이 결정한다.

주 문

이 사건 사유신고를 수리하지 아니한다.

이 유

신고인은, 이 법원 2018타채○○○○호 채권압류명령을 송달받은 것에 의하여 ○
○ 공탁소에 대해 민사집행법 제248조 제1항을 근거로 하여 2018년 10월분 임료에
관하여, 별지공탁목록 기재와 같이 공탁하고, 이 사건 사유신고서를 집행법원에 제
출하였다.

그러나 이 사건 기록에 의하면 신고인에게 위 명령이 송달된 것은 2018. 10. 1. 이
기 때문에 같은 해 9. 30.에 지급기가 도래한 2018년 10월분 임료채권에 대해서는
위 압류명령이 효력을 갖지 아니한다.

그렇다면, 이 사건 사유신고는 부적법한 공탁에 기초하여 된 것이므로 이를 수리하
지 않기로 하여 주문과 같이 결정한다.

20 . . .

판사 ○ ○ ○ (인)

[8 - 4] 제3채무자에 대한 사실조회서

○ ○ 지 방 법 원
사 실 조 회

김갑동 귀 하

사 전 20 타기 〇 〇 〇 〇 배당절차

채 권 자

채 무 자

제3 채무자

위 당사자간 별지 기재의 압류채권(또는 특허권 등의 그 밖의 재산권)에 대하여 다른 압류명령이나 가압류명령이 있는지 여부를 알고자 하오니 조속히 회보하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

판 사 (인)

민집규 184①

(주의) 송달받은 결정이 있을 때에는 그 사본을 첨부하시기 바랍니다.